



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.003175/2020-50.

Data do julgamento: 08/11/2022

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Acusados:

Jorge Eduardo Saraiva
Jorge Saraiva Neto
Olga Maria Barbosa Saraiva

Ementa: Irregularidades em processo de aumento de capital social, relativas a (i) diluição injustificada, em infração aos arts. 153 c/c 170, §§1º e 7º, da Lei nº 6.404/1976; e ao art. 2º, IX, do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480/2009; e (ii) conflito de interesses, em violação aos arts. 115, §1º, e 156 da Lei nº 6.404/197. Absoluções.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu por:

I. Por maioria, pela absolvição de Jorge Eduardo Saraiva, da acusação de exercício de voto em conflito de interesses, na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia (infração ao art. 156 da Lei 6.404/1976).

II. Por unanimidade, pela:

a. absolvição de Jorge Eduardo Saraiva, da acusação de exercício de voto em conflito de interesses, na qualidade de acionista controlador da Companhia (infração ao art. 115, §1º, da Lei 6.404/1976).

b. absolvição de Jorge Eduardo Saraiva, Jorge Saraiva Neto e Olga Maria Barbosa Saraiva da acusação de diluição injustificada (infração ao art. 153, c/c o art. 170, §§ 1º e 7º, da Lei 6.404, e ao art. 2º, inciso IX do Anexo 30-XXXII, da Instrução CVM 480/2009).

O julgamento deste processo foi iniciado em 16/08/2022, ocasião em que o Diretor Relator Alexandre Rangel votou pela: **(i)** não procedência da acusação de diluição injustificada formulada contra os acusados (suposta infração ao art. 153, c/c o art. 170, §§ 1º e 7º, da Lei 6.404/76, e ao art. 2º, inciso IX do Anexo 30-XXXII, da Instrução CVM 480); **(ii)** não procedência da acusação de exercício de voto em conflito de interesses formulada contra Jorge Eduardo Saraiva (na qualidade de acionista controlador da Companhia por suposta infração ao art. 115, §1º, da Lei 6.404/76); e **(iii)** não procedência da acusação de exercício de voto em conflito de interesses formulada contra Jorge Eduardo Saraiva (na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia por suposta infração ao art. 156 da Lei 6.404/76). O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, e o Diretor Otto Lobo acompanharam os fundamentos e as conclusões do voto do Diretor Relator, tendo apresentado manifestações de voto. Em seguida a sessão foi suspensa após pedido de vistas realizado pela Diretora Flávia Perlingeiro.

Presentes o advogado Guilherme Setoguti, representando os acusados Jorge Eduardo Saraiva e Olga Maria Barbosa Saraiva.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Otto Lobo, João Carlos Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro Barroso do Nascimento, que presidiu a Sessão.

A sessão foi reiniciada em 08.11.2022 e a Diretora Flávia Perlingeiro relatou divergência parcial quanto aos fundamentos e às conclusões apontados pelo Diretor Relator em relação às acusações em face de Jorge Eduardo Saraiva de violação (i) ao art. 115, §1º, da Lei 6.404, na qualidade de acionista controlador, por exercício abusivo do direito de voto, e (ii) ao art. 156 da Lei 6.404, na qualidade de membro do conselho de administração (CA), por ter votado na reunião do CA aprovando matéria na qual tinha interesse conflitante com o da Companhia. A Diretora apresentou sua divergência quanto à adoção da teoria do conflito material proposta pelo Diretor Relator em relação a ambas as acusações, sendo que votou **(i)** pela **absolvição** de Jorge Eduardo Saraiva, da acusação de exercício de voto em conflito de interesses, na qualidade de acionista controlador da Companhia (suposta infração ao art. 115, §1º, da Lei 6.404), ainda que por fundamento diverso do adotado pelo Diretor Relator; e **(ii)** pela **condenação** de Jorge Eduardo Saraiva, na qualidade de membro do conselho de administração da Saraiva, à multa de R\$ 210.000,00, por ter votado na reunião do CA de 3/11/2019, aprovando matéria na qual tinha interesse conflitante com o da Companhia (infração ao art. 156 da Lei 6.404). Quanto às demais acusações, acompanhou a conclusão do voto do Diretor Relator Alexandre Rangel pela absolvição dos acusados.

O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, e o Diretor Otto Lobo apresentaram manifestações de voto e acompanharam os fundamentos e as conclusões do voto do Diretor Relator.

Presente o Procurador Dr. Claudio Taufie Fontes representante da

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Otto Lobo, João Carlos Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 02/01/2023, às 14:59, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 03/01/2023, às 09:47, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 03/01/2023, às 10:11, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 03/01/2023, às 16:11, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 14/03/2023, às 11:02, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1646261** e o código CRC **4FF9985E**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1646261** and the "Código CRC" **4FF9985E**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.003175/2020-50

Reg. Col. nº 2007/20

Acusados: Jorge Eduardo Saraiva
Jorge Saraiva Neto
Olga Maria Barbosa Saraiva

Assunto: Apurar eventuais irregularidades em processo de aumento de capital social, em infração aos arts. 115, §1º; 153; 156 e 170 da Lei nº 6.404/1976; e ao art. 2º, IX do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480/2009

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Acompanho as conclusões expostas no muito bem fundamentado voto do Diretor Relator. Sem qualquer pretensão de exaurir o tema, entendo pertinente tecer considerações que julgo relevantes para análise de conflito de interesse, em especial quando examinado em caso de impedimento de voto do acionista em deliberações de assembleias.
2. A análise do conflito de interesses em voto do acionista em deliberação assemblear tem sido objeto de amplo debate doutrinário e no âmbito dos processos julgados pelo Colegiado desta Autarquia, que por diversas vezes oscilou quanto à aplicação das teorias *formalista* e *materialista* de conflito de interesses nas hipóteses previstas no §1º do art. 115 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”)¹.
3. Ciente das brilhantes contribuições feitas, há quase dois séculos, por renomados doutrinadores nacionais e estrangeiros acerca da teoria aplicável nesses casos, com excelentes fundamentos para ambos os lados, apresento esta manifestação de voto a fim de expor algumas

¹ Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas. § 1º o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

considerações pelas quais entendo que o conflito de interesses do acionista deve ser analisado sob a ótica material.

4. O §1º do artigo 115 da LSA prevê as quatro hipóteses de impedimento do acionista de voto nas deliberações assembleares: (i) aprovação do laudo de avaliação de bens com que concorre para a formação do capital social; (ii) aprovação de suas contas como administrador; (iii) matérias que puderem beneficiar o acionista de modo particular; e (iv) matérias em que tiver interesse conflitante com o da companhia.

5. Quanto à interpretação das duas primeiras hipóteses do §1º, é pacífico o entendimento de impedimento absoluto *ex ante*, que obstrui o acionista de exercer o seu direito de voto.

6. Com relação às terceira e quarta hipóteses do §1º, a LSA regula os casos de conflito de interesse como disciplina diversa das situações de impedimento objetivo de voto do acionista. Assim, estas duas disposições, de benefício particular do acionista e interesse conflitante deste com o da companhia, não trazem critérios objetivos e, portanto, não impedem que seja proferido um voto válido do acionista, que pode ser revisto em um exame *ex post* do caso concreto.

7. O conflito de interesse se caracteriza quando o interesse particular do acionista for colidente, antagônico, contrário e exercido em detrimento ao interesse social, e não apenas diferente ao da companhia².

8. Ademais, o §4º do art. 115 da LSA³ dispõe ser anulável a deliberação tomada “em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da companhia...”, sendo certo que o legislador optou por prescrever de forma expressa as hipóteses de proibição de votar *ex ante*,

² Segundo os ensinamentos de Carmem Alborch Bataller, o conflito de interesse apresenta as seguintes características: (i) a existência de uma situação oposta ou antagônica, objetiva e real entre os interesses do sócios e da sociedade; (ii) a existência de um nexo de causalidade entre o interesse extra-social ou privado do sócio em prejuízo do interesse social; (iii) o interesse extra-social ou particular do acionista ser próprio ou de terceiro; (iv) a natureza patrimonial do interesse do sócio em conflito; e (v) a irrelevância da intenção do sócio de causar dano à empresa e mesmo de seu conhecimento da existência de um conflito pessoal com a companhia. (BATALLER, Carmen Alborch El derecho de voto del accionista (supuestos especiales). Madrid Editorial Tecnos. 1977. pp. 262/264).

José Luiz Bulhões Pedreira, um dos coautores do anteprojeto da LSA, pontua que “[i]nteresse conflitante significa interesse oposto, contrário, incompatível ou colidente. Não é apenas interesse diferente ou distinto, que pode ser, inclusive, coincidente com o da companhia, ou complementar a este: é válido o voto proferido pelo acionista no interesse da companhia, ainda que na deliberação tenha outro interesse próprio, distinto do da companhia, desde que não seja com este conflitante” (Parecer elaborado no âmbito do Inquérito Administrativo CVM RJ nº 2002/1153. V. FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 2002, v. 128, p. 231).

³ § 4º A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

já estabelecendo a consequência da não abstenção em tais hipóteses como sendo a nulidade, e não anulabilidade, do voto.

9. Ao meu juízo, a opção do legislador pela necessária aplicação do conceito de conflito material se torna ainda mais evidente quando examinado o sistema da LSA que regula os grupos societários⁴ e, invariavelmente, transações entre partes relacionadas⁵⁻⁶, pois, devido à dinamicidade de suas atividades, sobretudo ante a atual realidade societária brasileira, não poderiam funcionar sem a tomada, quase que diária, de inúmeras decisões em potencial conflito de interesse.

10. A atual dinâmica empresarial, somada aos avanços tecnológicos e a um mercado cada vez mais competitivo, impõe que as tomadas de decisões sejam realizadas de forma rápida e ágil. Assim, uma avaliação *ex ante* das situações com potencial conflito de interesses pode causar efeitos deletérios na gestão das companhias⁷, ou até mesmo priva-las de oportunidades

⁴ Sobre o assunto, Viviane Muller Prado afirma que: “utilizando-se de metáforas, Ulrich Immenga afirma que, atualmente, a sociedade por ações não representa mais uma estrela independente, mas compõe uma galáxia (Company systems and affiliation, p.3)”. (PRADO, Viviane Muller. Conflito de Interesses nos Grupos Societários. São Paulo: Quartier Latin, 2006. P. 19, nota de rodapé nº 7)

⁵ Conforme leciona Viviane Muller Prado: “2.2 A participação da sociedade em um grupo não retira a sua condição de pessoa jurídica, com organização, interesses e patrimônio próprios. Para assegurar a autonomia da sociedade e garantir que os seus negócios sejam conduzidos conforme o seu interesse social, aplica-se a regra de conflito de interesses. Esta impõe limites à atuação do controlador e dos administradores da controlada. Ocorre que a rígida interpretação de tal regra, em especial conforme o critério formal e *a priori*, pode inviabilizar o funcionamento das estruturas grupais.

2.3 A política grupal pode se concretizar mediante a realização de operações e contratos entre sociedades do mesmo grupo. Para não viabilizar o funcionamento dos grupos, primeiramente pressupõe-se a interpretação substancial e *a posteriori* do disposto no art. 115, § 1º, última parte, da Lei 6.404/1976.” (PRADO, Viviane Muller. Conflito de Interesses nos Grupos Societários. São Paulo: Quartier Latin, 2006. P. 255 e 256)

⁶ A análise sob a ótica do conflito material permite discutir efetivamente o interesse da companhia. Não por acaso, as transações em que uma parte negocia consigo mesmo, em *self dealing*, tem como crivo o “entire fairness test” em cortes como Delaware, tribunal notoriamente especializado no assunto nos Estados Unidos. A parte interessada pode, então, demonstrar que a transação é resultado de “fair dealing” e reflete um “fair price.” (GOSHEN, Zohar. The Efficiency of Controlling Corporate Self-Dealing: Theory Meets Reality. In: California Law Review. Vol 91. 2º Ed. 2003). Este raciocínio pode ser encontrado em outras jurisdições, como no caso Foncière D’or vs. T-Rex Holding Invest B.V., em que os acionistas propuseram medida judicial alegando que o acionista controlador havia aprovado deliberação em benefício de seu controlador indireto, mas a corte encerrou o caso sob o fundamento de que a demandante não conseguiu demonstrar que: (i) foi privado de qualquer informação relevante sobre o negócio; (ii) a companhia havia deixado de aproveitar negócio mais vantajoso; e (iii) o controlador violou algum procedimento ou direito na condução dos negócios. Caso número 200.312.046/01. J. 21.07.2022. Disponível em: <https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2022:2217>

⁷ Neste sentido, o Diretor Relator Alexsandro Broedel Lopes, que defendeu a teoria do conflito formal, no caso Tractebel, ressaltou o seguinte: “57. Assim, receio que uma perspectiva muito rígida, que por vezes vigora para os defensores da doutrina do conflito formal, possa levar-nos a ignorar a capacidade do mercado de, por mecanismos de governança, criar formas de mitigação e até resolver o problema do conflito de interesses. Vale dizer, a defesa



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

empresariais, o que geraria graves ineficiências⁸⁻⁹. No meu entendimento, não foi esta a intenção do legislador.

11. Vislumbro, portanto, que o controle material do conflito de interesses também propicia uma maior eficiência econômica, sem prejuízo de os acionistas minoritários eventualmente lesados se socorrerem ao Poder Judiciário ou à arbitragem para pleitearem a anulação do voto e/ou respectivo ressarcimento de eventuais prejuízos oriundos do voto proferido em conflito de interesses.

12. Dessa forma, com base em uma análise sistemática e histórica da lei societária brasileira, me alio à posição majoritária da doutrina no sentido de que se deve realizar uma análise *ex post* do impedimento de voto do acionista nas duas hipóteses finais do §1º do art. 115 da LSA.

13. Organizei o meu voto em cinco seções: **(i)** direito ao voto do acionista; **(ii)** interpretação histórica e sistemática da LSA; **(iii)** evolução e garantias da tutela dos direitos dos minoritários; **(iv)** decisões da Comissão de Valores Mobiliários e do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional; e **(v)** conclusão.

I. Direito ao voto do acionista

14. O voto, no direito societário, consiste na manifestação unilateral do acionista acerca da sua vontade quanto à uma decisão coletiva a ser tomada pela sociedade. Nas palavras de Alfredo Lamy Filho, o direito de voto “*é instrumento para que cada acionista possa tomar parte na ação comum, contribuindo para a formação da vontade social*”¹⁰. Isto é, consiste no poder político do acionista influenciar na condução da atividade empresarial desenvolvida pela sociedade.

15. No entanto, uma das finalidades da criação da sociedade anônima foi possibilitar a captação de recursos da poupança popular — dinheiro das pessoas em geral — para o desenvolvimento, de

exacerbada da posição formalista pode, eventualmente, fechar os olhos para soluções interessantes que o mercado apresente, de acordo com cada caso concreto.” (Processo Administrativo nº RJ 2009-13179, j. em 09.09.2010).

⁸ Conforme as palavras do Diretor Marcos Barbosa Pinto em seu voto proferido no âmbito do Processo Administrativo CVM nº RJ2009/13179, j. em 09.09.2010.

⁹ Relevante o trecho do voto do Ministro Aldir Passarinho Junior no âmbito do Recurso Especial 131.300 – RS: “Na verdade, na sociedade comercial há conflitos de interesses e de força, prevalecendo a força do capital, porque isso é inerente à natureza da sociedade. Não existindo um interesse estritamente colidente de um acionista em relação à própria empresa, não há razão para se afastar da votação o acionista, no caso, o majoritário, ficando muito difícil se gerir uma sociedade, porque a todo momento se poderia interpretar que tal ou qual atitude deste acionista estaria ou não colidindo com o interesse daquela, quando é ele, por ter a maioria do capital, quem toma as decisões.” (STJ, 4ª Turma, Recurso Especial nº 131.300 – RS, Rel: Min. Cesar Asfor Rocha, j. em 29/8/2000, DJ. em 20/11/2000).

¹⁰ LAMY FILHO, Alfredo. A Lei das S.A. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 292.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

forma organizada e profissional, de atividades econômicas. Nesse contexto, aparece a figura do acionista investidor, cujo objetivo central é usufruir de rendimentos a serem gerados pela sociedade, e não participar de forma ativa da condução dos negócios sociais.

16. Consoante se inferia do Decreto nº 434 de 1891 e, depois, do Decreto-lei nº 2.627 de 1940 que o revogou, o legislador brasileiro estabeleceu que o direito de voto não constitui um direito essencial e intangível do acionista. Ao editar, em 1976, a Lei nº 6.404, o legislador manteve tal entendimento¹¹, conforme se constata da ausência de tal direito no rol do art. 109¹².

17. A lei societária vigente manteve a possibilidade de se estabelecer diferentes espécies e classes de ações, conferindo, via de regra, o direito de voto à todas as ações. No entanto, a redação do art. 111 da LSA, que trata das ações preferenciais, é expressa ao prever, desde que determinadas vantagens econômicas sejam atribuídas, a possibilidade de deixar de conferir a tais ações “*alguns dos direitos reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o de voto, ou conferi-lo com restrições*”, ainda que tais limitações e restrições não possam ser estabelecidas de forma absoluta, conforme se compreende do §1º do dispositivo mencionado¹³.

18. Nos termos do *caput* do art. 115 da LSA, o direito de voto deverá ser exercido, sempre, no interesse da companhia. Em outras palavras, o legislador estabeleceu — como princípio basilar do direito de voto — a prevalência do interesse da sociedade sobre o interesse individual do acionista. Segundo Fabio Konder Comparato e Calixto Salomão Filho, “*a todo poder correspondem deveres e responsabilidades próprias, exatamente porque se trata de um direito-função, atribuído ao*

¹¹ Sobre o assunto, cabe transcrever trecho da Exposição de Motivos da Lei nº 6.404/1976: “Seção II - Direitos Essenciais - O Projeto mantém a enumeração dos direitos essenciais da lei em vigor, mas amplia o direito de preferência para a subscrição de ações (art. 109, nº IV), estendendo-o aos bônus de subscrição e às partes beneficiárias e debêntures conversíveis em ações, pois a emissão desses títulos também pode ser (e já tem sido) usada pela maioria como instrumento de diluição dos acionistas minoritários. Esse direito está regulado nos artigos 172 e 173”. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/aceso-a-informacao-cvm/institucional/sobre-a-cvm/EM196Lei6404.pdf>

¹² Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembléia-geral poderão privar o acionista dos direitos de: I - participar dos lucros sociais; II - participar do acervo da companhia, em caso de liquidação; III - fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais; IV - preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172; V - retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei.

¹³ Art. 111. O estatuto poderá deixar de conferir às ações preferenciais algum ou alguns dos direitos reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o de voto, ou conferi-lo com restrições, observado o disposto no artigo 109. § 1º As ações preferenciais sem direito de voto adquirirão o exercício desse direito se a companhia, pelo prazo previsto no estatuto, não superior a 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos ou mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão até o pagamento, se tais dividendos não forem cumulativos, ou até que sejam pagos os cumulativos em atraso.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

titular para a consecução de finalidade precisas”¹⁴.

19. Ou seja, a lei societária não proibiu o acionista de votar com base em interesse próprio, contanto que tal interesse seja compatível com o interesse comum na realização do objeto social¹⁵.

20. Nesse sentido, todo voto que contrariar tal princípio básico, “*exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas*” (LSA, art. 115, *caput*), é considerado abusivo.

21. Com efeito, não obstante se tratar de um importante instrumento conferido aos acionistas, o direito de voto — legítimo e fundamental — pode ser limitado em situações específicas, desde que expressamente previsto em lei ou por ato de liberalidade entre particulares.

II. Interpretação histórica e sistemática da LSA

22. Conforme já apontado no item 4 deste voto, o § 1º, do art. 115 da LSA prescreve as quatro hipóteses em que o acionista está impedido de votar nas deliberações de assembleia geral.

23. De modo geral, como antecipado acima, não há na doutrina e na jurisprudência divergência de entendimento no sentido de que, em ocorrendo quaisquer das duas primeiras hipóteses (“i” e “ii”), fica caracterizado o impedimento absoluto do exercício do direito de voto pelo acionista¹⁶, estando impedido, *ex ante*, de votar, tendo em vista o princípio de que ninguém pode julgar em causa própria.

24. Por outro lado, o mesmo não se pode dizer da terceira e quarta hipóteses, sobretudo em razão dos conceitos indeterminados dos termos empregados pelo legislador (“benefício particular” e “conflito de interesses”), motivo pelo qual o tema é objeto de tempestuosos debates¹⁷.

¹⁴ O poder de controle na sociedade anônima. 5ª Ed. GEN, Editora Forense, 2008. p 363.

¹⁵ “O acionista pode votar segundo seu interesse próprio, desde que esse interesse não seja conflitante, mas compatível, com o interesse da companhia: o interesse da companhia na lei brasileira serve como regra de dever de atuar contida no direito de voto, como finalidade cuja realização o acionista deve sempre buscar no exercício de seu direito” (LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das companhias. 2ª Ed. GEN, Editora Forense, 2017. p. 296).

¹⁶ Neste sentido, o Parecer de Orientação CVM nº 34, de 18/08/06, afirma que: “A polêmica não alcançou, contudo, a vedação ao voto na aprovação do laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e aprovação de suas próprias contas como administrador. Essas hipóteses estão expressamente previstas no art. 115, § 1º, da Lei 6.404/76. Nesses casos, não há dúvida, seja na doutrina jurídica, seja nas decisões da CVM, de que o acionista (que integralizará o capital ou que seja administrador, conforme o caso) está previamente impedido de votar.

¹⁷ “O conflito formal se verifica apenas nas duas primeiras hipóteses previstas na parte inicial do art. 115, § 1º, quando a Lei das S.A. afirma que ‘o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas, como administrador (...)’. As demais, constantes da parte final do dispositivo (‘nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia’), dizem respeito a conflito



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

25. De todo modo, no presente processo, a análise será limitada à parte que toca ao conflito de interesses.
26. Inspirada em conceitos adotados na legislação estrangeira¹⁸⁻¹⁹, a lei societária brasileira trata conflito de interesse como disciplina distinta das situações de proibição objetiva de voto ao acionista²⁰.
27. Com efeito, para o interesse particular do acionista ser caracterizado como conflitante, não basta que seja distinto do interesse social, mas efetivamente incompatível ou colidente com

substancial, daí a necessidade de verificar, *in concreto*, se há benefício particular para o sócio, contrastante com o interesse da companhia, ou conflito de interesses.” (PENTEADO, Mauro Rodrigues. Reorganização operacional e societária. Ação Declaratória de nulidade de deliberações do Conselho de Administração de S.A. Suposto conflito de interesses. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. Malheiros: São Paulo, v. 146, abr/jun. 2007, p. 253)

¹⁸ No que se refere à conflito de interesses, a lei societária brasileira inspirou-se em conceitos das legislações alemã e italiana, incorporando, inclusive, redação semelhante.

O art. 2.373 do Código Civil Italiano prevê a hipótese de proibição ao voto (“Divieto di voto”) e de conflito de interesse: “Conflito d’interesi. — Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli há, per conto próprio o di terzi, um interesse in conflitto com quello della società. In caso d’inosseranza della disposizione del comma precedente la deliberazione qualora possa recare danno alla società, è impugnabile a norma dell’art. 2.377 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.” Em tradução livre: Conflito de interesses. O direito de voto não pode ser exercido pelo sócio em deliberações em que tenha por conta própria ou de terceiros um interesse em conflito com o da sociedade. Em caso de inobservância desse dispositivo que possa causar danos à sociedade, é impugnável, nos termos do art. 2.377, se sem o voto do sócio que deveria abster-se da votação não se teria formado a maioria necessária.

Já a lei de sociedade por ações alemã (*Aktiengesetz*) determina a proibição do exercício de voto, conforme dispõe o § 136, *Abs.* 1, que, em tradução livre, dispõe: “Ninguém pode exercer o direito de voto, por si mesmo ou por outra pessoa, quando uma decisão for tomada a respeito de sua própria exoneração, ou de ser dispensado ou liberado de uma obrigação, ou do exercício de um direito que a sociedade deva fazer valer contra o sócio votante”.

O § 243, *Abs.* 2, do mesmo diploma trata da anulação das deliberações: “a anulação pode também basear-se no fato de um acionista, no exercício do direito de voto, ter tentado obter vantagens particulares para si ou para terceiros em detrimento da sociedade ou de outros acionistas e a deliberação for apta para servir a este propósito” – em tradução livre.

¹⁹ Sobre o tema, Francesco Galgano aponta que “Ocorre conflito de interesses entre o sócio e a sociedade quando o sócio se encontra na condição de ser titular, diante de uma determinada deliberação, de um duplo interesse: do seu interesse de sócio e, por outro lado, de um interesse externo à sociedade; e esta duplicidade de interesses é tal que ele, o sócio, não pode realizar um sem sacrificar o outro interesse. Todavia a simples duplicidade de interesses em um mesmo sujeito, por si só, não implica situação de conflito no sentido técnico. As duas posições de interesse podem ser de solidariedade entre eles: o sócio pode realizar o próprio interesse sem prejudicar o interesse da sociedade” (Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico Dell’Economia, Defam Padova, 1988, v. 7, p. 251 - traduzido).

²⁰ Segundo as palavras de Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França: “nas hipóteses de proibição de voto, a lei alemã, com base em precisas circunstâncias formais, estabelece um controle *ex ante* de legitimidade do voto; violada a proibição, decorre a *consequência juris* da nulidade do voto e da anulabilidade da deliberação, se o voto for decisivo para a formação da maioria. Já no que tange ao conflito de interesses, há um controle *ex post*: torna-se necessária uma indagação relativamente ao mérito da deliberação, para a qual foi decisivo o voto do acionista, a fim de apurar se efetivamente ocorreu a incompatibilidade entre os seus interesses e o interesse da companhia, com prejuízo ao menos potencial para esta última (ou seja, cabe apurar se houve abuso no exercício do direito de voto)” (Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa. São Paulo: Malheiros, 2009, pgs. 337/338).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

este²¹⁻²².

28. O próprio legislador brasileiro definiu, na Exposição de Motivos da Lei nº 6.404/76, conflito de interesses como uma “*matéria delicada*” e defendeu a edição de uma lei societária com redação mais genérica, de modo a deixar “*à prática e à jurisprudência margem para a defesa do minoritário sem inibir o legítimo exercício do poder de maioria, no interesse da companhia e da empresa*”²³.

29. Em se tratando de norma de caráter genérico e abstrato, não vislumbro um impedimento, *ex ante*, baseado em eventual existência de conflito de interesses em tais hipóteses²⁴. Ao meu ver, a opção do legislador de não definir expressamente os critérios objetivos de apuração da existência de tal conflito — até porque não seria possível prever, de antemão, todas as hipóteses em que o interesse particular do acionista esteja antagônico ao interesse da companhia — foi justamente no sentido de garantir que esta avaliação seja realizada por meio de exame circunstanciado de cada caso, calcado em um controle *ex post factum*.

²¹ Nessa mesma linha, cabe transcrever voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos no Inquérito Administrativo CVM nº TA-RJ2002/1153, j. em 06.11.2002: “*Em outras palavras, não basta que haja uma duplicidade de interesses no voto do acionista. Para que se caracterize o conflito de interesses mencionado na lei, tal duplicidade deve implicar obrigatoriamente um choque de interesses, uma colisão entre o interesse social e o do acionista, de modo que um não poderia prevalecer sem o sacrifício do outro*”.

²² Segundo Bartolomeo Quatraro: “*V'è conflitto di interessi, fra socio e società solo quando il primo si trovi nella condizione di essere portatore, di fronte ad una data delibe razione, di un duplice interesse: del suo interesse di socio ed, inoltre, di un interesse esterno alla società e questa duplicità di interessi è tale per cui egli non può realizzare l'uno se non sacrificando l'altro interesse (cioè l'interesse della società); ne consegue che non v'è conflitto quando l'interesse del socio coesiste, senza contrapporsi con quello so ciale*”. Em tradução livre: Só existe conflito de interesses entre sócio e sociedade quando aquele se encontra na condição de ser portador, face a determinada deliberação, de um duplo interesse: do seu interesse de sócio e, ainda, de um interesse externo ao da sociedade e essa duplicidade de interesses é tal que ele não pode realizar um a não ser sacrificando o outro interesse (isto é, o interesse da sociedade); assim não há conflito quando coexiste o interesse do acionista, sem contrastar com o social”. (QUATRARO, Bartolomeo. Le operazioni sul capitale; aumenti e riduzioni del capitale sociale, prestiti obbligazionari, azioni proprie. Milano, Giuffrè, 1994. p. 615).

²³ “O artigo 115 cuida dos problemas do abuso do direito de voto e do conflito de interesses entre o acionista e a companhia. Trata-se de matéria delicada em que a lei deverá deter-se em alguns padrões necessariamente genéricos, deixando à prática e à jurisprudência margem para a defesa do minoritário sem inibir o legítimo exercício do poder de maioria, no interesse da companhia e da empresa.” Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/acesso-a-informacao-cvm/institucional/sobre-a-cvm/EM196Lei6404.pdf>

²⁴ Neste sentido, cabe citar trecho do Voto proferido pelo Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos no Inquérito Administrativo CVM Nº TA-RJ2002/1153, julgado em 06 de novembro de 2002: “44. Em minha opinião, quando há referência genérica, que me parece ser o melhor sistema, o tratamento deve ser aquele agasalhado pela remansosa doutrina e jurisprudência (i.e. substancial, colidente, estridente, não formal, etc...), pois dada a subjetividade da avaliação e a largueza do conceito, parece-me impensável que a avaliação primeira do conflito de interesse fosse de outra pessoa que não o acionista interessado, pois só ele poderá, antes mesmo de proferir o voto, avaliar se está em conflito de interesses ou não com a companhia na deliberação, inclusive porque somente ele sabe o teor do voto que proferirá, até mesmo em razão de o conflito poder resultar de uma situação que nem transpareça formalmente, mas onde ainda assim exista o conflito”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

30. Afinal, o § 4º do art. 115 da LSA prescreve ser anulável — e não nula — a deliberação tomada em decorrência de voto de acionista em interesse conflitante com o interesse social. Caso o legislador entendesse que o acionista estivesse, *ex ante*, proibido de votar em situações de conflito de interesses, a norma teria estabelecido a nulidade (e não anulabilidade) do voto.

31. Nada impede que o acionista, de maneira legítima, faça uso do seu direito de voto para atingir, eventualmente, um interesse pessoal, desde que o faça sem sacrificar o interesse social²⁵.

32. Nesse sentido, entendo que o impedimento *a priori* de votar em situação de possível conflito de interesses vai de encontro ao princípio da presunção da boa-fé, eis que se presume que o acionista em posição conflitada tomará medidas em prejuízo da companhia, em descumprimento à obrigação legal de votar em conformidade com o interesse social²⁶⁻²⁷.

33. Aliás, a Lei nº 13.874/19, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, dispõe expressamente, em seu art. 3º, inciso V, ser direito de toda pessoa física e jurídica “gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial”, o que reforça, a meu ver, a corrente material do conflito de interesses²⁸.

34. De igual modo, o impedimento absoluto do direito de votar nessas situações esbarra no princípio majoritário — um dos pilares do direito societário²⁹ —, na medida em que o acionista

²⁵ Endossando o entendimento, Marcelo Lamy Rego esclarece: “(...) Nada impede que o acionista sacrifique seu interesse pessoal, estranho à comunhão, em prol do interesse social - que está obrigado por lei a satisfazer. A presunção deve ser a de que o acionista vá agir de acordo com a lei e não o contrário, com o bom senso pode nos fazer crer em algumas situações” (REGO, Marcelo Lamy. Direito das Companhias, 1º vol., 1º Ed. Forense, 2009, p. 425)

²⁶ Como bem pontuado pelo então Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, em seu voto proferido no Inquérito Administrativo CVM n RJ2002/1153: “[s]eria como imaginar que devemos manter preso alguém que pode vir a cometer um crime, preventivamente, antes que qualquer crime seja cometido, apenas para evitar que ele possa eventualmente vir a cometer este crime”.

²⁷ A atenção ao princípio da boa-fé não tem limite no seu aspecto subjetivo, ausência de má-fé, mas abrange seu sentido objetivo, lealdade nas relações, o que foi positivado, quase trinta anos depois da LSA, no art. 422 do Código Civil de 2002. A boa-fé já determinava a interpretação dos negócios jurídicos, consoante o art. 113 do mesmo diploma. Cito aqui entendimento do STJ: “O princípio da boa-fé objetiva, em matéria societária, deve ser interpretado à luz das práticas do mercado de capitais, títulos e valores mobiliários e dos princípios e normas que as informam, todos extraídos das leis especiais que regem esse mercado”. (REsp n. 1.162.117/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2012, DJe de 20/11/2014.)

²⁸ Em comparação com o direito público, o Código de Processo Civil utiliza o impedimento para diversos participantes do processo, incluindo o juiz, como forma proteger a imparcialidade do processo de cognição a fim de resultar numa decisão justa e resposta legítima à pretensão das partes. O impedimento, que na literalidade também parece absoluto, é interpretado pelos tribunais com rigorosa análise, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas e exigindo comprovação do dano consecutório, em deferência ao princípio *pas de nullité sans grief*.

²⁹ Segundo os ensinamentos de Francesco Galgano em sua clássica obra sobre a história do princípio majoritário nas deliberações: “[A] maioria nada mais é do que o resultado de um cálculo aritmético; metade mais um dos votos faz



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

controlador é quem mais aportou capital na sociedade (possuindo maior alinhamento de interesses com a companhia que os acionistas minoritários, haja vista ser o maior afetado economicamente com o desempenho daquela sociedade) e via de regra possui mais *expertise* sobre os negócios, é excluído do processo de formação da vontade social³⁰.

35. O conflito de interesse, pois, nem sempre é tão claro, de modo que seja possível constatar a sua existência de forma eminentemente objetiva, a ponto de tolher o exercício de direito fundamental do acionista de votar, o que evidencia a importância em se analisar cada situação de forma particular, verificadas as peculiaridades de cada caso.

36. A propósito, na ocasião da reforma da LSA³¹, em 2001, houve uma tentativa de inclusão de novos parágrafos no artigo 115³², no sentido de garantir aos acionistas minoritários detentores de determinado percentual de participação do capital social, competência para convocar assembleia geral para deliberar quanto à existência de conflito de interesses a fim de impedir o acionista conflitado de exercer seu direito de voto.

37. Entretanto, os dispositivos foram objeto de veto pelo então Presidente da República, sob a seguinte justificativa:

"A necessidade de se vetar os parágrafos acima transcritos [§ 5º ao § 10 do art. 115] decorre de manifesto conflito com o interesse público, em razão da constatação de que a

com que a vontade ou a opinião de uma parte prevaleça sobre a vontade ou opinião de outra parte. E esta aritmética também pode ser tomada como um valor absoluto: não é este ou aquele voto que decide, exclamou Honoré-Gabriel de Mirabeau na assembleia constituinte nascida da Revolução Francesa, mas "a comparação da soma daqueles que dizem sim com a soma daqueles que dizem não". (GALGANO, Francesco. La forza del numero e la legge della ragione – Storia del principio di maggioranza. Bologna: Editora Il Mulino, 2007, p-93 – em tradução livre).

³⁰ Marcelo Lamy Rego pontua que "[c]omo observa SOPRANO (1914, p.130), são duas as regras que norteiam as decisões da Assembleia Geral: que a vontade manifestada pelo acionista não pode ser considerada como tendente à tutela do particular, mas ao interesse social – no momento da formação da vontade coletiva todas as vontades dos sócios são, ou se presume que sejam, dirigidas por um interesse coletivo; e que, na divergência das vontades particulares, a vontade da maioria prevaleça sobre a vontade da minoria (princípio majoritário)" (REGO, Marcelo Lamy. Direito das Companhias, 1º vol., 1º Ed. Forense, 2009, p. 402)

³¹ Por meio da Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001.

³² "§ 5º Poderá ser convocada assembleia-geral para deliberar quanto à existência de conflito de interesses e à respectiva solução, por acionistas que representem 10% (dez por cento), no mínimo, do capital social, observado o disposto no parágrafo único, alínea c, parte final, do art. 123. § 6º A assembleia a que se refere o § 5º também poderá ser convocada por titulares de ações com direito a voto que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante. § 7º No curso da assembleia-geral ordinária ou extraordinária, os acionistas a que se refere o § 6º poderão requerer que se delibere sobre a existência de conflito de interesses, não obstante a matéria não constar da ordem do dia. § 8º Decairão do direito de convocar a assembleia de que trata o § 5º os acionistas que não o fizerem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que tiverem ciência inequívoca do potencial conflito de interesses. § 9º Caso a assembleia-geral, por maioria de votos, delibere haver conflito de interesses, deverá especificar as matérias nas quais o acionista em situação de conflito ficará impedido de votar. § 10. A assembleia especificada no § 9º poderá delegar, com a concordância das partes, à arbitragem a solução do conflito." (sic)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

assembléia para deliberação acerca da existência de conflito de interesses de que tratam os citados dispositivos se afigura inócua em termos de proteção ao acionista minoritário. Com efeito, não há como afastar o voto do acionista controlador no conclave pretendido – sob pena de se atribuir aos minoritários o inédito poder de, indiretamente, vetar qualquer deliberação a partir da alegação de existência de conflito do controlador, e de se desconsiderar o próprio conflito de interesses do minoritário na assembléia especial, o que demonstra a inexistência de efetividade na proposta apresentada.

Em realidade, as regras acima enfocadas trariam, na prática, apenas confusão, podendo, inclusive, servir para supostamente confirmar a inexistência de um conflito cuja presença caberia ao Poder Judiciário avaliar, ou mesmo para motivar um aumento de ações judiciais envolvendo o controvertido tema de que se cuida.”³³ (grifei).

38. Dessa forma, com base em uma análise sistemática e histórica da lei societária brasileira, me alio à posição majoritária da doutrina no sentido de que se deve realizar uma análise *ex post* do impedimento de voto do acionista nas duas últimas hipóteses do §1º do art. 115 da LSA.

III. Evolução e garantias da tutela dos direitos dos minoritários

39. Importante destacar que a teoria do conflito material, de forma alguma, causa um eventual desamparo aos demais acionistas em face de deliberação social em que o interesse da companhia foi prejudicado por um voto em conflito.

40. A própria LSA, em sua redação original, já traz previsão neste sentido nos §§ 3º e 4º do art. 115. Nestes casos, restando a companhia inerte, a demanda pode ser proposta por acionista ou grupo de acionistas constituindo 5% do capital social, em que se substituiu a legitimidade ativa da companhia contra o administrador ou acionista controlador³⁴

41. Posteriormente, a Lei nº 10.303/01 incluiu o §3º no art. 109, permitindo a utilização da arbitragem como uma alternativa para a resolução de conflitos societários. O instrumento tornou-se mais eficaz com a inclusão do art. 136-A pela Lei nº 13.129/15, que passou a obrigar todos os acionistas quando a cláusula estiver incluída no estatuto da companhia³⁵.

³³ Mensagem nº 1.213, de 31 de outubro de 2001, da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2001/Mv1213-01.htm

³⁴ REsp n. 1.214.497/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/9/2014, DJe de 6/11/2014.

³⁵ Os acionistas e o mercado também podem vir a obter reparação em decorrência da mobilização do Ministério Público, da CVM ou de associação que tenha entre suas finalidades institucionais objeto correlato, conforme a legitimidade concedida nas Leis n. 7.347/85, n. 7.913/89 e 8078/90. A Ação Civil Pública claramente é um instrumento similar às ações coletivas americanas, *class actions*, reguladas pela *Federal Rule 23*, aplicada, por exemplo, no ajuizamento de ação contra a Petrobrás em favor dos titulares de *American Depositary Receipts* que tinha como fundamento o dano a investidores em virtude de *fraud on the Market*. São exemplos de casos similares: Banco Panamericano (TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação 1089065-29.2013.8.26.0100, Rel.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

42. Aliás, percebe-se um aumento significativo do número de acionistas minoritários buscando, por variadas razões (inclusive, por alegado conflito de interesses), reparação em face de acionistas controladores — ou mesmo da própria companhia, em casos específicos — com o crescimento da arbitragem no Brasil.
43. Dado o caráter célere, confidencial e especializado do instituto, a B3 estabeleceu, com exceções dos segmentos Básico e Nível I, a obrigatoriedade das companhias listadas nos demais segmentos da bolsa aderirem à Câmara de Arbitragem do Mercado para a resolução de conflitos.
44. Os atuais meios de comunicação permitem uma maior articulação entre acionistas minoritários, o que impulsionou o surgimento das chamadas arbitragens coletivas³⁶, relevantes instrumentos de tutela coletiva de direitos dos acionistas no mercado de capitais brasileiro³⁷.
45. Além disso, o desenvolvimento do *litigation finance* (financiamento de litígios por terceiros) no Brasil consiste em importante ferramenta de acesso à justiça ou às câmaras arbitrais, para acionistas minoritários, eis que possibilita buscarem indenização por danos causados por acionistas controladores mediante o custeio do procedimento arbitral ou judicial por terceiro (muitas vezes fundos de investimentos especializados) atrelado a uma porcentagem de retorno referente ao benefício econômico a ser possivelmente auferido.
46. No mesmo sentido, as mídias sociais, que abrangem todos os canais utilizados para compartilhar conteúdo e possibilitar a interação entre as pessoas, propiciou um enorme incremento do ativismo societário, que, como comumente veiculado, foi relevante na divulgação das demandas a serem propostas por acionistas em sede arbitral ou no Judiciário.
47. A própria CVM editou, em 2022, a Resolução nº 80, que dispõe sobre o registro e a prestação de informações periódicas e eventuais dos emissores de valores mobiliários admitidos à

Ramon Mateo Júnior, j. 10.04.2015.); ABN/Banco Real (TJSP, 5.ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 9247433-87.2005.8.26.000, Rel. Christine Santini, j. 23.11.2011; Embargos Infringentes 9247433-87.2005.8.26.0000/50002, Rel. Moreira Viegas, j. 28.08.2013.); Cobrasma (TJSP, 1.ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 94/431-4/4, Rel. Des. Elliot Akel, j. 30.05.2000.); OGX (Decisão da 7.ª Vara Empresarial da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, Processo 0085670-76.2015.8.19.0001 (2015.8.19.0001), Sentença 15.05.2016, Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana.); Arapuã (Ação Civil Pública 0015278- 16.2004.403.6100 e Processo Administrativo sancionado da CVM: PAS 31/00.); LAEP (5.ª Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo, Ação Civil Pública 005926-19.2013.403.6100).

³⁶ Instituto que se aproxima das “class actions” norte-americanas.

³⁷ Cabe ressaltar a análise realizada pelo Desembargador Cesar Ciampolini, no âmbito da Tutela Cautelar Antecedente nº 2090011-46.2020.8.26.0000: “A admissibilidade do procedimento arbitral coletivo, portanto, merece reflexão (...) Reflexão acerca, por exemplo, do estímulo para que frutifiquem entre nós ações coletivas, com o fito de pacificação social, uniformidade na distribuição do direito, etc. Trata-se da incessante busca de se ter um direito processual eficaz, ligado aos direitos materiais e às garantias que deve concretizar. No caso do mercado de capitais, vital para a economia do País, as ações coletivas são, realmente, de se cogitar. (...) Plausível possa haver a arbitragem coletiva”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários, que prevê, especificamente no seu Anexo I, o que se considera demanda societária e as informações relevantes a serem prestadas envolvendo todo processo judicial ou arbitral cujos pedidos estejam, no todo ou em parte, baseados em legislação societária ou do mercado de valores mobiliários, ou nas normas editadas pela CVM.

48. Assim, é flagrante a relevante evolução das garantias do direito dos acionistas minoritários e em geral de buscar reparação de eventuais danos causados por acionistas controladores, na medida em que diversos obstáculos anteriormente existentes foram removidos ou se tornaram diminutos pelos avanços acima citados.

IV. Decisões da CVM e do CRSFN

49. A partir do exame dos precedentes da CVM ao longo dos últimos 20 anos, não é possível concluir pela adoção de uma corrente específica, seja material ou formal, de forma clara e consistente em seus julgamentos. De todo modo, entendo que o exame de tais precedentes contribui significativamente para o amadurecimento da interpretação do §1º do art. 115 da LSA, ao registrarem um percurso de juízo: os pressupostos, os fundamentos e suas conclusões.

50. Em apertada síntese, aqueles que defendem a teoria formalista argumentam que o acionista em situação de conflito está impedido, em controle prévio, de votar em virtude de um interesse extrassocial que viciaria sua vontade e, por consequência, seu voto³⁸.

51. Os defensores da teoria materialista, por sua vez, entendem ser descabido presumir um vício na vontade do acionista, sob o fundamento de ser necessário verificar se o voto proferido efetivamente contraria o interesse social, de modo que o controle só pode ser realizado *ex post facto*. Este entendimento procura privilegiar o direito de voto dos acionistas, parte necessária do princípio majoritário, e a presunção da boa-fé, no sentido de que, não obstante possuírem interesses individuais, acionistas podem votar sem prejuízo do interesse da companhia³⁹.

52. De modo a ilustrar o acima disposto, destaco os casos mais paradigmáticos enfrentados pela CVM e pelo CRSFN nos últimos vinte anos⁴⁰:

³⁸ Foram defensores desta corrente os Diretores Alessandro Broedel Lopes, Norma Parente, Otávio Yazbek, Marcos Barbosa Pinto, Luciana Dias, Pablo Renteria, Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Gustavo Borba, Henrique Machado bem como Presidentes Maria Helena Santana, Leonardo Gomes Pereira e Marcelo Barbosa.

³⁹ Entre seus principais defensores estiveram Luiz Leonardo Cantidiano, Luiz Antonio Sampaio Campos, Wladimir Castelo Brando Castro, Eli Loria e Gustavo Gonzalez.

⁴⁰ Outros casos também apreciados pela CVM:

Caso Ambev: Em 16.12.2004, foi julgado recurso contra decisão da área técnica, no âmbito do Processo RJ2004/5494, em que o Colegiado examinou a alienação de controle da Companhia de Bebidas da América – Ambev via permuta



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de ações com a Interbrew S.A. A controvérsia residiu no direito de voto dos controladores da Ambev em relação à deliberação de incorporação da Labatt Brewing Canadá Holding Ltd., pois a Ambev havia se obrigado perante a Interbrew de votar favoravelmente.

Também por maioria, o Colegiado posicionou-se no sentido de que o conflito de interesses seria material e, portanto, o controle deveria ser exercido *ex post*. A Diretora Norma Parente, vencida, reiterou em seu voto que o conflito de interesses seria formal, em razão da incorporação da sociedade não poder ser analisada separadamente da operação de permuta de ações, persistindo o conflito de interesses.

Caso Eneva: Em 25.08.2015, a CVM analisou a consulta administrativa RJ-2015-5021 formulada pela FIA Dinâmica, acionista minoritário da Eneva S.A. – Em Recuperação Judicial, sobre deliberação relativa ao aumento de capital desta. Em especial, se havia impedimento dos acionistas Eike Batista e a empresa alemã E.ON em relação ao aumento de capital com aporte de ativos da E.ON na companhia.

Segundo o acionista minoritário, a E.ON, na qualidade de credora da Eneva e detentora de ativos que nela seriam aportados, obteria benefício particular na deliberação do aumento de capital, e Eike Batista possuiria interesse conflitante com o da companhia, por força de suas relações com os principais credores da companhia, além de estar impedido de votar em virtude de regra constante de acordo de acionistas celebrado com a E.ON.

A área técnica da CVM entendeu que a E.ON teria aprovado indiretamente o laudo de avaliação dos seus próprios bens em razão de uma Carta de Confirmação de Apoio em que o BTG e Petra se comprometeram a aprovar o laudo de avaliação dos bens da E.ON e esta aprovaria o laudo de avaliação dos bens da BTG e Petra.

Com base principalmente na teoria formalista, o Colegiado da CVM, por unanimidade, concluiu que não ficou comprovada a existência de hipótese legal de impedimento de voto hábil a proibir Eike Batista de votar nas deliberações e, por maioria, que a E.ON estaria impedida de votar.

Caso Emae: Em 14.07.2017, foi examinado o Processo CVM nº RJ 19957.005749/2017-29, que tinha como objeto o exercício de voto do Estado de São Paulo em assembleia geral da Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. – EMAE no tocante a deliberação sobre proposta de acordo entre a EMAE e a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a qual é controlada pelo Estado de São Paulo, em uma solução relativa à indenização decorrente do fornecimento de recursos hídricos de uma para a outra. O Relator Presidente Leonardo Pereira adotou a teoria formal e entendeu que a existência de conflito de interesses seria evidente. Declarou haver, no caso, interesses externos envolvidos que poderiam comprometer a imparcialidade do acionista, caracterizando a existência de um conflito de interesses.

O Diretor Pablo Renteria conceituou o conflito de interesses sempre que houver interesse oposto ou paralelo ao da companhia, desde que flagrante, acompanhando os fundamentos do Presidente Relator. O conflito de interesses não se limitaria aos contratos em que uma das partes é o próprio acionista, podendo ser aplicado às suas controladas, direta ou indiretamente. O Diretor Henrique Balduino Machado Moreira acompanhou seu voto.

O Diretor Gustavo Borba também se alinhou à teoria formal. No entanto, apesar de concluir pela existência de um conflito de interesses potencial, em razão do Estado de São Paulo ser o único titular de ações com direito a voto na EMAE, não haveria qualquer situação de impedimento de voto.

O Diretor Gustavo Machado Gonzalez proferiu voto divergente da maioria, filiando-se à corrente substancialista. Desta forma, votou pela possibilidade do exercício do direito de voto pela Emae.

Por maioria, prevaleceu no Colegiado da CVM a teoria formalista, ao identificarem o conflito de interesses em razão da existência, no caso, de interesses externos envolvidos que poderiam comprometer a imparcialidade do acionista.

Caso JBS: Em 29.08.2017, foi examinado pelo Colegiado o Processo CVM 19957.007563/2017-12, em que o BNDES Participações S.A., acionista da JBS. S.A., apresentou pedido de interrupção do curso do prazo de antecedência de convocação de assembleia geral extraordinária. Entre seus fundamentos, que em relação ao item “v” da ordem do dia, dois acionistas seriam beneficiários diretos dos contratos de indenidade a serem firmados pela JBS, evidenciando um impedimento de voto decorrente de um conflito de interesses.

área técnica desta Autarquia entendeu que embora o conflito de interesses em si não enseje a interrupção do curso do prazo da AGE, o objetivo do art. 124, §5º, II, da Lei nº 6.404/76 é evitar a ocorrência de deliberações irregulares. Assim, a CVM, em sendo possível, deveria se manifestar sobre o impedimento de voto, permitindo aos acionistas a oportunidade de tomar decisões mais bem refletidas.

No entanto, o Colegiado, por unanimidade, evidenciou uma inclinação pela teoria material, ao entender que as informações presentes no caso não permitiram concluir pelo impedimento de voto, necessitando aprofundamento das questões de fato e de direito da matéria. Para o momento, restaria aos próprios acionistas avaliar se estão em situação de conflito de interesses com relação às deliberações em questão, devendo, se for o caso, absterem-se de exercer seu



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Caso TIM

53. Em 19.12.2001, foi julgado o PAS CVM nº RJ2001/4977, que tinha como objeto o exercício do direito de voto da acionista controladora direta, Tele Sul Celular Participações S.A., em assembleia geral da CTMR Celular S.A. que deliberou sobre negócio jurídico entre a controladora indireta, Telecom Itália Mobile, e a companhia.

54. Filiando-se à corrente da teoria formal, o Colegiado, por maioria⁴¹, condenou a acionista controladora pelo exercício do direito de voto em potencial conflito de interesses. A Diretora Relatora Norma Jonssen Parente — acompanhada pelo Diretor Wladimir Castelo Branco de Castro e o Presidente José Luiz Osório de Almeida Filho — fundamentou sua decisão considerando que a acionista controladora figuraria nos dois lados da relação contratual, em negócio consigo mesmo, e por não ter sido demonstrado aos demais acionistas que o contrato atendia condições equitativas e comutativas.

55. Ao apreciar o recurso interposto, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”) manteve a decisão da CVM. No voto vencedor do Conselheiro Edson Garcia, restou decidido que seria possível conciliar as duas teorias existentes (formal e material): podendo a avaliação do conflito ser feita *a priori*, pelo próprio acionista, ou *a posteriori*, após o voto, quando arguido por outro acionista.

Caso Previ

56. Em 06.11.2002, foi julgado o PAS CVM nº RJ2002/1153, que teve como objeto o exercício

direito de voto na AGE.

Posteriormente, em 17.04.2018, foi examinado pelo Colegiado o Processo 19957.010393/2017-45, consistente em consulta formulada pelo BNDES Participações S.A. sobre a legalidade do exercício de voto pelas companhias acionistas controladas pelo Srs. Wesley e Joesley Batista nas matérias voltadas à adoção de medidas de responsabilização de acionistas controladores e administradores da JBS e inclusão de cláusula estatutária prevendo a possibilidade de celebração de contratos de indenidade pela JBS S.A.

A área técnica novamente concluiu pela existência de impedimento de voto das companhias controladas pelos interessados em potencial conflito com a JBS S.A.

O Colegiado, por unanimidade, não conheceu a consulta, por ausência de previsão legal, ressaltando que prevaleceria em relação à matéria o entendimento manifestado pela área técnica que concluiu, em resposta à consulta, que havia impedimento de voto das companhias controladas para participar de eventual deliberação para propositura de ação em desfavor de seus controladores.

⁴¹ Vencido, o Diretor Marcelo Trindade concordou com o impedimento de voto, mas considerando a ocorrência de benefício particular e não de conflito de interesses. Em seu entendimento, as hipóteses perceptíveis de benefício ao acionista, não extensível aos demais ou a companhia não se enquadrariam, *strictu sensu*, em conflito de interesses. Ao apresentar voto de divergência, votando pela absolvição da acionista controladora, o Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos sustentou que deveria ser adotada a teoria do conflito material, também discordando da questão do benefício particular apontada pelo Diretor Marcelo Trindade, privilegiando o direito de exercício do direito de voto do acionista.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

do direito de voto de dois acionistas indiretos, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e a Fundação Sistel de Seguridade Social, em assembleia da Tele Norte Leste que deliberou sobre um contrato de prestação de serviços gerenciais a ser celebrado entre a Telemar Participações, companhia nas quais os acionistas tinham participação, e companhias controladas pela Tele Norte Leste.

57. Por maioria, a CVM absolveu os acusados, prevalecendo a corrente materialista de conflito de interesses⁴².

58. Ao julgar o recurso de ofício, o CRSFN reformou a decisão, fazendo prevalecer a teoria do conflito formal.

Caso Tractebel

59. Em 09.09.2010, a CVM analisou a Consulta CVM nº RJ2009/13179, formulada pela Tractebel Energia S.A., sobre a possibilidade de o seu acionista controlador GDF Suez Energy Latin America Participações Ltda. votar em deliberação sobre transação de compra de 100% das ações da Suez Energia Renovável S.A. também controlada pelo seu controlador.

60. Adotando a teoria do conflito formal, o Colegiado, por maioria⁴³, entendeu que a

⁴² O Presidente Luiz Leonardo Cantidiano entendeu que se a deliberação não puder beneficiar o acionista de modo particular ou se seu interesse extrassocial estiver sintonizado com o interesse social, ele poderá votar. No caso, julgou que os interesses não eram conflitantes.

O Diretor Luiz Antônio Sampaio Campos divergiu quanto à abrangência do conceito de conflito de interesse, reafirmando seu entendimento de que o conflito deve ser substancial, efetivo e inconciliável. Ponderou, ainda, que deve prevalecer o princípio da presunção de boa-fé em favor do acionista, não se podendo concluir antecipadamente sobre a intenção de votar em desfavor da companhia.

O Diretor Wladimir Castelo Branco Castro sustentou que o conflito deve ser analisado a posteriori, após a ocorrência efetiva do voto abusivo ou, no caso específico, em conflito com os interesses da companhia.

A Diretora Relatora Norma Jonssen Parente, que restou vencida, fundamentou sua decisão com base na teoria do conflito formal, ratificando seu entendimento que conflito deve ser compreendido em sentido lato: “[a] *lei sequer permite que se discuta a significância do conflito. Simplesmente, havendo conflito, proíbe o voto*”. Diferenciou o voto em conflito do voto abusivo, o qual, este sim, demandaria uma análise substancial do voto, enquanto na situação de conflito, a lei teria instaurado uma proibição cautelar do exercício do poder de voto, concluindo pela inadmissibilidade do exercício do voto em razão do interesse decorrente de possuírem participação acionária, ainda que minoritária, na Tele Norte Leste e na Telemar, condenando-os.

⁴³ O Diretor Relator Alexsandro Broedel Lopes, seguindo a teoria do conflito formal e considerando aspectos informacionais, partiu da premissa de que existia assimetria informacional entre controlador e os minoritários no caso analisado e que o impedimento legal do acionista interessado, especialmente quando controlador, força um equilíbrio entre acionistas ao forçá-lo a elaborar uma proposta que atenda minimamente os interesses dos demais acionistas. Ou seja, o impedimento incentiva um equilíbrio informacional como consequência. Ainda que seja analisado caso a caso, cita interpretação de Fábio Konder Comparato ao apontar que “o conflito de interesses pode ser verificado tanto a priori, nos casos em que se possa ser facilmente evidenciado, quanto a posteriori, mas situações em que não transpareça de maneira reluzente”. Assim, o acionista não poderia participar de deliberação sobre contrato em que é parte. O Diretor Otavio Yazbek também se filiou à corrente formal.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

controladora direta estaria impedida de votar, apesar da Tractebel ter criado um comitê especial independente, na forma prevista no Parecer de Orientação CVM nº 35, com o objetivo de mitigar a questão do potencial conflito de interesses.

Caso Eletrobrás

61. Em 26.05.2015, foi julgado o PAS CVM nº RJ2013/6635 que tratou o exercício de voto pela União Federal na deliberação pela renovação das concessões de geração e transmissão de energia elétrica das companhias controladas pela Eletrobrás⁴⁴.

62. Aplicando a teoria formalista, o Colegiado, por unanimidade⁴⁵, entendeu que a União Federal votou em conflito de interesses, violando o art. 115, §1º, da LSA.

63. Em sede de recurso, o CRSFN, por maioria⁴⁶, com voto de qualidade da Presidente Ana

O Diretor Marcos Barbosa Pinto, também seguindo a teoria formal, entendeu que a celebração de um contrato entre o acionista e a companhia caracterizaria a um só tempo benefício particular e conflito de interesses. Entre seus fundamentos, defendeu que a escolha da lei pelo impedimento a priori de voto existiria para prevenir prejuízos à companhia na situação em que haja um risco de que o acionista atue no interesse próprio em um contexto que as demandas judiciais não responsabilizariam os acionistas em tempo razoável. Entre seus fundamentos econômicos, sustentou que não há razão para que os acionistas minoritários votem contrariamente às matérias que sejam do interesse da companhia, em resposta a um dos argumentos utilizados pela teria material, de que a limitação de voto teria um efeito deletério nas sociedades por ações.

A Presidente Maria Helena Santana apresentou declaração de voto também se posicionando pela aplicação da corrente formal, apontando que a situação de contratar com a companhia, ainda que em condições comutativas, constitui um benefício particular, não extensível aos demais acionistas, e, por consequência, torna o acionista impedido de votar. Por fim, vencido, o Diretor Eli Loria sustentou que o conflito de interesses deve ser analisado posteriormente ao exercício do voto, com base na interpretação sistemática da LSA: “é permitido ao acionista controlador votar desde que se atenha aos deveres do art. 115, caput, e do art. 116, parágrafo único, e, faltando a esse dever, o voto abusivo é anulável e, caso tenha sido determinante, a própria deliberação será anulável”.

⁴⁴ Na ocasião, a totalidade dos votos favoráveis à renovação foi proferida pela União e por empresas sob o seu controle, enquanto quase a totalidade dos acionistas minoritários presentes foram contrários.

⁴⁵ A Relatora Diretora Luciana Dias, acompanhada pelos demais integrantes do Colegiado (Diretores Pablo Renteria, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente Leonardo Gomes Pereira), apontou que a deliberação em análise tratou de contrato entre partes relacionadas, em que o acionista está em posição oposta à da companhia, o que configuraria o impedimento de voto por conflito de interesses.

⁴⁶ Conforme o voto do Relator Flávio Maia Fernandes dos Santos, a análise do art. 115, no caso, exigia uma interpretação sistemática com o art. 238, de forma que, “tanto sob a perspectiva do conflito formal de normas, quanto do substancial, tem-se que obrou com acerto a União ao exercer o direito/dever de votar na forma em que fez na referida AGE da Eletrobrás”.

Na mesma oportunidade, o Conselheiro Sérgio Cipriano dos Santos declarou: “Em primeiro lugar, apesar de entender que a Teoria do Conflito Formal é aplicável, não considero que a aplicação dela permita uma decisão diferente daquela apresentada no voto do Conselheiro Relator, ou seja, o provimento ao recurso da União”.

O Conselheiro Alexandre Henrique Graziano, por sua vez, manteve a decisão da CVM: “a satisfação do interesse público não pode ser invocada como razão para afastar o impedimento de votar do acionista controlador de sociedade de economia mista em uma situação de conflito de interesses”

Eu, na qualidade de Conselheiro, tive a possibilidade de me posicionar na oportunidade, e, após exame do caso sob a ótica da teoria do conflito material, decidi pela manutenção da decisão da CVM. Também votaram pela manutenção da decisão da CVM os Conselheiros Carlos Portugal Gouvêa e Thiago Paiva Chaves.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Maria Melo Netto Oliveira, reverteu a decisão da CVM, concluindo pela improcedência da acusação. Conforme o voto do Relator Flávio Maia Fernandes dos Santos, a análise do art. 115, no caso, exigia uma interpretação sistemática com o art. 238, de forma que, *“tanto sob a perspectiva do conflito formal de normas, quanto do substancial, tem-se que obrou com acerto a União ao exercer o direito/dever de votar na forma em que fez na referida AGE da Eletrobrás”*.

Caso Linx

64. Em 13.11.2020, foi julgado o Processo CVM nº 19957.005563/2020-75, consistente em recurso interposto contra decisão da área técnica que tinha como objeto o exercício de voto de três acionistas, na assembleia geral extraordinária da Linx S.A. nas deliberações acerca de operação de incorporação de ações da Linx S.A. pela STNE Participações S.A. considerando a celebração de contratos de indenização por não concorrência e da proposta de contratação com os acionistas recorrentes⁴⁷.

65. Seguindo a teoria formal, o Colegiado, por maioria⁴⁸, concluiu pela inoccorrência da hipótese de benefício particular ou de conflito de interesses apto a gerar impedimento de voto dos acionistas recorrentes.

Caso Cyrela (FII Grand Plaza)

66. Em 25.05.2021, foi julgado o Processo CVM nº 19957.00837/2021-11, referente a recurso interposto contra decisão da área técnica que entendeu que a cotista majoritária estaria em conflito de interesses ao votar em assembleia de cotistas nas deliberações relativas à cisão de fundo de investimento, parte de uma reestruturação proposta pelos cotistas minoritários em resposta à

⁴⁷ Em que pese o impedimento da área técnica tenha concentrado seu fundamento na existência de benefício particular e o art. 115, § 1 da LSA, o Colegiado trouxe importantes observações sobre a aplicação do mesmo artigo em situações de conflito de interesses.

⁴⁸ O Diretor Henrique Balduino Machado Moreira considerou os recorrentes impedidos, pois, ainda que se desconsiderasse a análise do eventual benefício particular, verificou, no caso, a incidência do conflito formal quanto ao potencial interesse conflitante entre os recorrentes e a Linx S.A.

O Presidente Marcelo Barbosa e a Diretora Flávia Perlingeiro apresentaram divergência, apontando que o benefício particular deve ocorrer na qualidade de acionista e resultar na quebra da isonomia de tratamento, bem como ter relação direta com a deliberação, de modo que não haveria benefício particular no caso, apenas contraprestação, e uma vez que não existia flagrante contraposição entre os interesses dos recorrentes e o interesse social, não teria ficado configurado um conflito de interesses apto a gerar impedimento por parte dos recorrentes, sem prejuízo de eventual controle *a posteriori* do voto efetivamente manifestado em face do interesse social.

O Diretor Alexandre Rangel acompanhou este entendimento da inexistência de benefício particular no caso, mas acrescentou que ainda que a LSA não autoriza o impedimento *a priori* de acionista na hipótese de conflito de interesses, ainda que flagrante.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

potencial risco tributário. A Receita Federal teria autuado o fundo como pessoa jurídica, aplicando entendimento que um fundo imobiliário está sujeito à mesma tributação das pessoas jurídicas caso aplique recursos em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, cotista com mais de 25% de suas cotas.

67. O Colegiado, por maioria⁴⁹, reformou a decisão da área técnica com fundamentos da teoria material de conflito de interesses, permitindo o exercício do direito de voto pela cotista majoritária na referida deliberação.

68. Como já adiantado, não se consolidou uma jurisprudência pacífica sobre o tema. Há votos que prevaleceram muito bem fundamentados que adotaram a teoria formal e outros, também vencedores, que se fundamentam na teoria material do conflito de interesses.

IV. Conclusão

69. A análise histórica e sistemática da LSA, somada aos princípios majoritário e presunção de boa-fé e o fortalecimento dos meios de tutela reparatória dos direitos dos acionistas minoritários no mercado de capitais brasileiro não se coaduna com a adoção de uma análise formal no tocante ao impedimento de voto por acionistas nas hipóteses ora analisadas do §1º do art. 115 da LSA, razão pela qual adoto a teoria materialista de conflito de interesses.

70. Por todo o exposto, acompanho os fundamentos e as conclusões do Diretor Relator e voto pela absolvição dos Acusados.

É como voto.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2022.

⁴⁹ O Diretor Alexandre Rangel discordou integralmente da área técnica. Em seus fundamentos, destacou a importância do princípio majoritário e observou que as limitações ao direito de voto, incluindo aqui o impedimento, são exceções e, nessa qualidade, devem ser interpretadas restritivamente. O inciso VI do §1º do art. 24, da Instrução 472/2008, com redação que guarda imensa similaridade com a parte final §1º do artigo 115 da LSA, não autorizaria o impedimento a priori do exercício do direito de voto. Não haveria conflito de interesses no caso e o administrador fiduciário não teria qualquer direito ou dever de impedir o exercício de direito de voto por cotista. Cabe apenas ao próprio cotista suscitar seu conflito de interesses.

O Presidente Marcelo Barbosa manifestou-se no sentido de que não ficou demonstrado no caso que os interesses seriam necessariamente contrapostos, incompatíveis ou inconciliáveis. Também concordou que caberia ao cotista reconhecer a situação de conflito de interesses e seu impedimento.

Em divergência com os demais membros do Colegiado, a Diretora Flávia Perlingeiro, vencida, concordou com a área técnica ao entender que havia potencial conflito de interesses, situação apta a gerar impedimento de voto da cotista majoritária. Observou, também, que seria possível fazer uso do art. 24, §2º, inciso II, da ICVM 472/2008, mecanismo que permitiria que os cotistas não conflitados deliberassem pelo afastamento do impedimento.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.003175/2020-50

Reg. Col. 2007/20

Acusados:

Jorge Eduardo Saraiva

Jorge Saraiva Neto

Olga Maria Barbosa Saraiva

Assunto:

Apurar eventuais irregularidades em processo de aumento de capital social, relativas a (i) diluição injustificada, em infração aos arts. 153 c/c 170, §§1º e 7º, da Lei nº 6.404/1976; e ao art. 2º, IX, do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480/2009; e (ii) conflito de interesses, em violação aos arts. 115, §1º, e 156 da Lei nº 6.404/1976

Relator:

Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto:

Presidente João Pedro Barroso do Nascimento

I - Introdução

1. Como bem pontuado no Relatório e no Voto do Dir. Relator Alexandre Costa Rangel, trata-se de processo em face de **(i)** Jorge Eduardo Saraiva, acionista controlador e membro do conselho de administração da Saraiva Livreiros S.A. – Em Recuperação Judicial (“Saraiva” ou “Companhia”); **(ii)** Jorge Saraiva Neto, conselheiro de administração da Companhia; e **(iii)** Olga Maria Barbosa Saraiva, conselheira de administração da Saraiva (“Olga”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.gov.br/cvm

Saraiva” e, em conjunto com Jorge Eduardo Saraiva e Jorge Saraiva Neto, “Acusados”), em que a Acusação traz imputações de:

- (i) Diluição injustificada. O primeiro assunto consiste na suposta ocorrência de diluição injustificada no processo de aumento de capital social aprovado na reunião do conselho de administração realizada em 03.11.2019 (“RCA”). Por isso, foi imputada em face de todos os Acusados, na qualidade de membros do conselho de administração, violação ao **art. 153 c/c art. 170, §§ 1º e 7º, da Lei nº 6.404/1976; e art. 2º, inciso IX do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480/2009;**
- (ii) Conflito de interesses. O segundo diz respeito ao exercício abusivo do direito de voto de Jorge Eduardo Saraiva na aprovação da capitalização do AFAC detido por ele contra a Companhia. Nesse sentido, **(a)** como acionista controlador, foi acusado de violação ao **art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976**, por ter votado favoravelmente à aprovação da matéria na assembleia geral extraordinária realizada em 31.10.2019 (“AGE”); e **(b)** como membro do conselho de administração da Companhia, foi acusado de violação ao **art. 156 da Lei nº 6.404/1976**, pelo exercício do direito de voto na RCA, aprovando matéria na qual possuía interesse conflitante com o da Companhia.

II – Diluição injustificada



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.gov.br/cvm

2. Em relação à acusação de diluição injustificada, acompanho o entendimento do Diretor Relator no sentido de que não houve diluição injustificada no Aumento de Capital aprovado na RCA, uma vez que:

- (i) o Aumento de Capital era necessário e o preço de emissão foi fixado de acordo com o critério de perspectiva de rentabilidade futura e dentro de parâmetros previstos no **art. 170, §1º, da Lei nº 6.404/1976**;
- (ii) não há evidências de que o preço de emissão, abaixo do valor de cotação em bolsa, foi estabelecido de forma artificial, de modo a promover a diluição desproporcional dos acionistas que não acompanhassem o Aumento de Capital;
- (iii) o preço de emissão e seu respectivo critério são desdobramentos do Plano de Recuperação Judicial (Doc. SEI nº 1149087), não tendo sido definidos isoladamente pelos Acusados; e
- (iv) o preço de emissão foi resultado de processo decisório razoável e bem-informado (*reasonable decision-making process*), com base em Laudo de Avaliação (Doc. SEI nº 11499091) e Parecer Técnico (Doc. SEI nº 1149092), que contemplaram informações e documentos capazes de proporcionar assessoria técnica especializada, útil e conveniente ao exame do conteúdo do tema, inclusive com relação aos aspectos econômicos que determinaram a escolha do critério adotado, em observância ao disposto no **art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/1976**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.gov.br/cvm

III – Conflito de interesses

3. Para além da acusação sobre diluição injustificada, o caso reascende a polémica do conflito de interesses e traz consigo a controvérsia relativa à escolha do ***critério formal*** ou do ***critério substancial*** para determinar a existência ou não do conflito de interesses no exercício do direito de voto em sociedades anônimas.

4. O voto do Diretor Relator já se aprofundou nas principais questões teóricas, com análise de doutrina e jurisprudência, o que, no caso concreto, me permite ser mais conciso e objetivo.

5. Resumidamente, a reflexão central sobre o **conflito de interesses** é antiga e se refere à interpretação do **art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976**, em que:

- (i) de um lado, pelo *critério formal*, entende-se que diante de uma situação de potencial conflito de interesses o acionista *ex ante factum* está proibido de exercer o direito de voto na matéria submetida à Assembleia Geral; e
- (ii) de outro lado, pelo *critério substancial*, admite-se que em casos de potencial conflito de interesses o acionista exerça o direito de voto e, *ex post factum*, após a análise material do caso concreto, caso se verifique que o voto foi exercido em violação ao interesse social: (i) o voto conflitante será declarado nulo; (ii) a deliberação com que este



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.gov.br/cvm

voto concorrer para sua aprovação será anulada, devendo ainda (iii) o acionista em conflito responder pelos danos causados e (iv) transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido, como determina o **artigo 115, §4º, da Lei nº 6.404/1976**.

6. Tenho convicção de que o *critério substancial* é o que melhor se aplica para a disciplina do conflito de interesses no exercício do direito de voto em Assembleias Gerais de sociedades anônimas, sendo essa a visão que tenho defendido há anos¹, seguindo a melhor doutrina sobre a matéria² e acompanhando casos paradigmáticos da CVM³.

7. Entretanto, é importante que se diga, que é justamente por defender o *critério substancial* que a tarefa de julgar um caso como este se torna ainda mais difícil, uma vez que é necessária a análise cuidadosa dos fatos e das características do caso concreto, a fim de se verificar se após o exercício do direito de voto houve *de fato* conflito de interesses e, desse modo, poder se determinar se o caso é passível de *condenação* ou *absolvição*.

¹ NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. *Conflito de Interesses no Exercício do Direito de Voto nas Sociedades Anônimas*. In Temas de Direito Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2022. pág. 39, em republicação do artigo originalmente publicado em **RDB (1ª Parte)**, v. 24, 2004, pp. 140-156, **RDB (2ª Parte)**, v. 25, 2004, pp. 82-103.

² Em benefício da objetividade, refiro-me a “FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. **Conflito de Interesses nas Assembléias de S.A.** São Paulo: Malheiros Editores, 2ª ed./2014”, em referência aos muitos autores que já escreveram em defesa do critério substancial.

³ Como exemplo, cita-se os casos: (i) Inquérito Administrativo nº TA-RJ2002/1153, Dir. Rel. Voto Vencedor Wladimir Castelo Branco, j. 06 de novembro de 2002; (ii) Processo CVM nº RJ2004/5494, Dir. Rel. Wladimir Castelo Branco, j. 14 de dezembro de 2004; (iii) PA CVM nº RJ2009-5811, Rel. SEP, j. 28.07.2009; e (iv) Processo CVM nº 19957.007563/2017-12, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. 29 de agosto de 2017.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.gov.br/cvm

8. As reflexões casuísticas sobre conflito de interesses dialogam diretamente com a própria análise da acusação de diluição injustificada formulada em face dos Acusados. Portanto, no meu entendimento, não procedem as acusações de abuso do poder de voto em decorrência de manifestação de voto em conflito de interesses ou em benefício particular formuladas em face do acusado Jorge Eduardo Saraiva.

(i) como acionista controlador da Companhia, de infração ao **art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976**, uma vez que:

(a) Não houve abuso do direito de voto (cf. *caput* do art. 115 da Lei nº 6.404/1976), considerando que os requisitos exigidos para sua configuração não estão presentes *in casu*;

(b) O art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976 não proíbe o acionista previamente de votar nos casos em que supostamente há conflito de interesses, sendo necessária a análise casuística da substância do voto exercido e o contexto em que o direito de voto se deu para que se pudesse concluir pela regularidade ou não do voto, o que apenas pode ocorrer *a posteriori*. Dentro desta lógica, analisei as características do caso concreto e não verifiquei interesse particular efetivamente colidente e inconciliável com o interesse da Companhia, não tendo se demonstrado dano, atual ou potencial, para a Companhia resultante do voto exercido;

(c) não há, no mérito do voto proferido pelo acusado Jorge Eduardo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.gov.br/cvm

Saraiva, interesse conflitante com os da Companhia, havendo na verdade, em sentido oposto, uma convergência de interesses, em contexto muito peculiar de Recuperação Judicial em que a Companhia precisava de aportes de capital, a fim de enfrentar grave situação de crise econômico-financeira; e

(d) também não há benefício particular no voto proferido pelo Acusado na AGE, na medida em que foi outorgado aos demais acionistas da Companhia o direito de subscrever as novas ações no âmbito do Aumento de Capital.

(ii) como membro do conselho de administração da Companhia, de violação ao **art. 156 da Lei nº 6.404/1976**, uma vez que:

(a) adoto a tese do conflito material e, portanto, não entendo adequada a proibição prévia à atuação do administrador;

(b) após avaliação do mérito sobre os interesses envolvidos, entendo que a manifestação do acusado na RCA se deu em atenção aos interesses da Companhia, uma vez que o Aumento de Capital e o preço de emissão das ações estabelecido convergiu com o previsto no item 11.6 (iii) do Plano de Recuperação Judicial (Doc. SEI nº 1149087) e com os interesses da Companhia;

(c) sendo assim, não restou configurado no caso concreto um interesse conflitante do administrador com os interesses da Companhia, não existindo, portanto, violação ao **art. 156 da Lei nº**



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.gov.br/cvm

6.404/1976.

9. Registrada a minha absolvição em relação a todas as imputações *in casu*, peço atenção às hipóteses em que é recomendada a abstenção de administradores e/ou acionistas em deliberações sociais. No caso concreto, por exemplo, a eventual abstenção de voto de Jorge Eduardo Saraiva na Reunião do Conselho de Administração do dia 03 de novembro de 2019 ainda resultaria na aprovação das matérias e evitaria alguns dos elementos da imputação do Termo de Acusação submetidos à apreciação do Colegiado desta autarquia⁴.

10. Além disso, o Parecer CVM nº 35/2008, apesar de abordar hipóteses de operações societárias envolvendo a sociedade controladora e suas controladas ou sociedades sob controle comum, leciona que procedimentos objetivos podem (*e devem*) ser adotados pelos administradores para a garantia do cumprimento de seus deveres fiduciários.

11. Finalizo com a mensagem de que este caso é paradigmático em relação à sedimentação do conflito material com esta atual composição do Colegiado da CVM⁵.

⁴ Na oportunidade da Reunião do Conselho de Administração (Doc. SEI nº 1149094), as pautas foram aprovadas por unanimidade dos conselheiros, de modo que os quóruns de instalação e de deliberação haviam sido atendidos, não existindo a necessidade do voto do Sr. Jorge Eduardo Saraiva para a aprovação das matérias.

⁵ O critério material do conflito de interesses foi recentemente defendido pelo próprio Diretor Alexandre Costa Rangel em caso referente ao artigo 156 da Lei 6.404/1976 (PAS CVM nº RJ2018/8272, Rel. Flavia Perlingeiro, j. 23 de março de 2021).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.gov.br/cvm

12. A controvérsia entre *critério formal* e *critério material* é antiga no Brasil e o posicionamento desta Autarquia se alterou em algumas ocasiões no passado em função da composição dos integrantes do Colegiado. Diante dessa incerteza, trabalharemos em um posicionamento institucional para dar mais previsibilidade aos regulados e integrantes do mercado de capitais sobre o tema.

IV – Conclusão

13. Por todo o exposto, acompanho os fundamentos e as conclusões do Diretor Relator e voto pela absolvição dos Acusados das imputações formuladas pela Acusação.

É como voto.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2022.

João Pedro Barroso do Nascimento
Presidente



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.003175/2020-50

Reg. Col. 2007/20

Acusados: Jorge Eduardo Saraiva

Jorge Saraiva Neto

Olga Maria Barbosa Saraiva

Assunto: Apurar eventuais irregularidades em processo de aumento de capital social, relativas a (i) diluição injustificada, em infração aos arts. 153 c/c 170, §§1º e 7º, da Lei nº 6.404/1976; e ao art. 2º, IX, do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480/2009; e (ii) conflito de interesses, em violação aos arts. 115, §1º, e 156 da Lei nº 6.404/1976.

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto: Diretora Flávia Perlingeiro

VOTO VISTA

1. Na sessão de julgamento de 16.08.2022, pedi vista dos autos deste processo administrativo sancionador (“PAS”)¹ para examinar mais detidamente os fatos e as controvérsias em tela. Retomando o julgamento do caso, faço referência ao bem lavrado voto do Diretor Relator Alexandre Rangel, para acompanhá-lo, em suas razões e conclusões, no que tange às acusações formuladas em face dos Acusados, na qualidade de membros do conselho de administração (“CA”) da Saraiva, de violação ao art. 153 c/c art. 170, §§1º e 7º, da Lei nº 6.404/1976 (“LSA”) e ao art. 2º, inciso IX, do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480/2009, então vigente, pertinentes à alegação de ocorrência de diluição injustificada no processo de aumento de capital social, aprovado na reunião do CA realizada em 03.11.2019, afastadas pelo Relator com propriedade.

2. Contudo, apresento, respeitosamente, minhas razões de divergência parcial em relação aos fundamentos e conclusões apontados pelo ilustre Diretor Relator no que diz respeito às seguintes acusações formuladas em face de Jorge Eduardo Saraiva (“Acusado”): (i) de violação ao art. 115, §1º, da LSA, na qualidade de acionista controlador, por exercício abusivo do direito de voto² na AGE de 31.10.2019; e (ii) de violação ao art. 156 da LSA, na qualidade de membro do CA, por ter votado na RCA aprovando matéria na qual tinha interesse conflitante com o da Companhia.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no voto do Diretor Relator ou no respectivo Relatório, conforme o caso.

² Ainda que o Termo de Acusação (“TA”) se refira, na proposta de responsabilização, ao exercício abusivo do direito de voto, sem mencionar ali a questão do conflito de interesses, a capitulação adotada (art. 115, §1º) e a narrativa acusatória não deixam dúvida de que o alegado abuso restaria configurado, na visão da Área Técnica, pela violação ao impedimento que reputou existir em razão de interesse conflitante do acionista, do que, inclusive, se defendeu plenamente o Acusado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

3. Para maior clareza e tendo em vista as especificidades do disposto no art. 115, §1º, e no art. 156 da LSA, abordarei tais acusações separadamente nas seções a seguir, sem qualquer pretensão de esgotar o debate acerca de todos os aspectos relevantes sobre os referidos temas.

Impedimento de Voto do Acionista Conflitado - art. 115, §1º, da LSA

Considerações Gerais

4. No que toca à acusação formulada quanto ao suposto exercício abusivo do direito de voto, pelo Acusado, na AGE de 31.10.2019, vale começar repisando o previsto no art. 115 da LSA:

“Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto **no interesse da companhia**; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.

§ 1º O **acionista não poderá votar** nas **deliberações da assembleia-geral** relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou **em que tiver interesse conflitante com o da companhia**. (...)” (grifos adotados)

5. O cerne da questão polêmica em apreço diz respeito à interpretação do disposto no referido dispositivo legal.

6. A respeito, tornou-se, de longa data, notória a polarização entre as teorias do conflito formal e do conflito material, construídas doutrinariamente, para lidar com as dificuldades de interpretação quanto ao que constitui “interesse conflitante” para fins de aplicação do art. 115. Ao longo de décadas, foi se formando um conjunto de precedentes relevantes³, em que a aplicação de tais teses foi proposta como chave para a solução dos casos concretos, via de regra com manifestações

³ V., p. ex., para citar alguns dos casos mais emblemáticos decididos pelo Colegiado da CVM em relação ao conflito de interesses de acionista (art. 115 da LSA): Inquérito Administrativo (“IA”) RJ2001/4977 (“Caso TIM”), Diretora Relatora Norma Parente, j. em 19.12.2001 (prevaleceu conflito formal, mas houve manifestação de voto pelo conflito material); IA RJ2002/1153 (“Caso Previ - Telenorte/Telemar”) Diretora Relatora Norma Parente (votou pelo conflito formal, mas restou vencida), voto condutor Diretor Wladimir Castelo Branco, j. em 06.11.2002 (prevaleceu conflito material); Processo Administrativo (“PA”) RJ2004/5494 (“Caso AMBEV”), Diretor Relator Wladimir Castelo Branco, d. em 16.12.2004 (prevaleceu não se tratar de questão de conflito de interesses, mas houve manifestações de voto pelo conflito formal e pelo material); PA RJ2009/13179 (“Caso Tractebel”), Diretor Relator Alexandre Broedel Lopes, d. em 09.09.2010 (prevaleceu conflito formal, mas houve manifestação de voto pelo conflito material); PAS RJ2013/6635 (“Caso Eletrobras”), Diretora Relatora Luciana Dias, j. em 26.05.2015 (por unanimidade pelo conflito formal); PA RJ2015/5021 (“Caso Eneva”), Diretor Relator Pablo Renteria, j. em 25.08.2018 (prevaleceu o conflito formal); PA 19957.005563/2020-75 (“Caso Linxs/Stone”), j. em 13.11.2020 (prevaleceu entendimento pelo não impedimento de voto na AGE, sem que, contudo, tenha sido adotada para atingir tal conclusão a teoria do conflito material, objeto apenas de posição divergente à época vencida, no caso). Quanto ao Caso Eletrobras, registre-se, ainda, que a decisão da CVM foi reformada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”), em 28.06.2017, no âmbito do recurso 14.306, Rel. Cons. Flávio Maia, após o que, de todo modo, a CVM divulgou comunicado reiterando seu posicionamento.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de voto divergentes (seja num ou noutro sentido), ainda que a lei propriamente dita não faça qualquer menção aos termos “formal” ou “material”.

7. Inicialmente, cabe reconhecer que, embora a ótica do conflito formal venha prevalecendo na CVM – notadamente há mais de uma década⁴ e até aqui –, o histórico anterior de casos aponta para uma certa alternância entre posições vencidas e vencedoras⁵ quanto à aplicação da teoria do conflito material, variando em consonância com mudanças de composição do Colegiado – mudanças essas que, aliás, são ínsitas à dinâmica de formação do órgão, à luz da disciplina legal que prevê, a cada ano, a substituição de ao menos um de seus integrantes, por ocasião do término do respectivo mandato, e que, por vezes – e não raro – acaba ocorrendo em maior constância em certos períodos, diante de eventuais renúncias ou do tempo tomado para o preenchimento de vagas.

8. Assim sendo, cabe ressaltar que, mesmo vindo a prevalecer, neste PAS, a abordagem sob o prisma do conflito material – considerando o teor dos votos já proferidos –, não se pode disso inferir se estar diante de um novo entendimento consolidado da CVM que seria capaz de, em tese, propiciar previsibilidade para os regulados e ao mercado de capitais em geral e segurança jurídica. A meu ver, infelizmente, diante da ausência de detalhamento, na própria LSA, quanto a como se configura ou se qualifica o conflito de interesses, e por se tratar, em essência, de embate interpretativo, a tendência é de que seja necessária uma mudança legislativa (já há muito cogitada e debatida em iniciativas legislativas diversas), a fim de conferir clareza de tratamento de modo mais perene e robusto⁶.

9. Isso sem descartar avanços regulatórios⁷, em acréscimo aos aprimoramentos promovidos

⁴ Ilustrando a prevalência da análise pelo prisma do conflito formal, a SEP fez referência, no TA, aos seguintes casos decididos pela CVM: PA RJ2009/5811 (“Caso Duratex-Satipel”), Diretor Relator Marcos Barbosa Pinto, d. em 28.07.2009; Caso Tractebel (2010), Caso Eletrobras (2015) e Caso Eneva (2015).

⁵ Assim, considerando as decisões do Colegiado da CVM, tomadas em PAS e PA em relação a conflito de interesses de acionistas (art. 115, § 1º, da LSA) nos últimos 20 anos, verifica-se prevalência do conflito formal em 2002; do conflito material entre 2002 e 2009 (por oito anos); e novamente do conflito formal de 2009 até hoje (por mais de doze anos).

⁶ Mesmo alguns dos defensores da linha do conflito material defendem a pertinência de alteração legislativa para conferir tratamento mais moderno ao tema. Nesse sentido, por exemplo, a manifestação de voto do então Diretor da CVM Gustavo Machado Gonzalez, no julgamento do PAS CVM nº RJ2016/7929, j. em 29.09.2020: “*Sobre esse ponto, reitero o meu entendimento de que a lei societária hoje emprega a expressão “interesse conflitante” em uma acepção técnica, que não abrange toda situação em que o acionista (no caso do art. 115, §1º) ou o administrador (no caso do art. 156) possuem um interesse extrassocial. Creio que, na atual redação da lei, as duas hipóteses de conflito de interesses dizem respeito somente àquelas situações em que o acionista ou o administrador possuem um interesse conflitante com o da companhia e votam em sacrifício do interesse social – que somente podem ser verificadas ex post factum –, muito embora esteja convicto sobre a necessidade de uma alteração legislativa para modernizar o tratamento da matéria*” (grifos aditados); valendo registrar, ainda, que as proposições do ex-Diretor para uma possível reforma da LSA nesse sentido já tinham sido expostas em mais detalhe na manifestação de voto que apresentou no PA CVM nº 19957.005749/2017-29 (“Caso Emae”).

⁷ Cite-se, p.ex., mudanças recentes na LSA, trazidas pela Lei nº 14.195, de 26.08.2021, com vistas à promoção de melhorias no ambiente de negócios no Brasil, inclusive quanto à proteção de acionistas minoritários, e, ainda, seus reflexos na regulamentação da CVM, com a edição da Resolução CVM nº 168, de 20.09.2022, como a previsão de que o voto plural não se aplica a votações da assembleia geral de acionistas que deliberem sobre transações com partes relacionadas que devam ser divulgadas nos termos do Anexo F da Resolução CVM nº 80, de 29.03.2022 (art. 45-A).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

no regime informacional relativo às transações com partes relacionadas, para além do que exigem as normas contábeis internacionais, bem como iniciativas de adoção, pelas companhias, de mecanismos voltados ao controle, à legitimação ou à mitigação dos riscos relacionados a situações de potencial conflito de interesse, desde que respeitados os limites decorrentes dos ditames legais em vigor, como já se observa em certas políticas de transações entre partes relacionadas⁸ e práticas adotadas no Brasil por grandes companhias, notadamente aquelas que contam com investimento estrangeiro substancial.

10. Importa, assim, admitir que, em que pese a longevidade e o brilhantismo com que estruturada a LSA – merecida e notoriamente reconhecida como um dos melhores diplomas legais de nosso ordenamento jurídico – a disciplina conferida a essa matéria, em específico, revelou-se insuficiente para lidar com a complexidade dos casos vivenciados, em especial aqueles em que o conflito de interesses não é manifestamente evidente. Na prática, isso acabou dando ensejo a interpretações que, a meu sentir, se descolam, por demais, da norma de vedação de exercício do direito de voto estabelecida por lei, acrescentando “requisito” de materialização de dano não previsto pela LSA para fins de configuração do impedimento de voto em razão de “interesse conflitante”⁹.

11. Com efeito, a meu ver, a teoria do conflito material parece ignorar o fato de que a LSA estabeleceu, expressamente, no art. 115, § 1º, que o “acionista não poderá votar” nas deliberações assembleares que tratem (i) do laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social, (ii) da aprovação de suas contas como administrador, (iii) em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou (iv) em que tiver interesse conflitante com o da companhia – e não fez qualquer distinção, entre tais quatro hipóteses, seja em relação ao momento, seja quanto ao modo de apurá-las.

12. Todavia, quanto ao interesse conflitante, a teoria do conflito material estabelece que o conflito não pode ser aferido *a priori* nem *ex ante*, já que não se configuraria independentemente do conteúdo do voto proferido e que, sob tal lente, nem sequer terá existido caso não se materialize dano à companhia. Nesse sentido, desconsidera a conflituosidade inerente à situação em que, por exemplo, haja clara contraposição de interesses em situação com flagrante aptidão para causar dano, tendo em vista que, segundo sustenta, só o próprio acionista saberia em que sentido pretende exercer seu voto e, com isso, se privilegiaria, ou não, interesses próprios em detrimento do interesse social.

13. Ainda sob a ótica do conflito material, não se poderia presumir a fraqueza humana ou a

⁸ No âmbito da autorregulação, há iniciativas que incentivam a adoção de boas práticas de governança corporativa para lidar com problemas insitos às transações entre partes relacionadas; v., p.ex., art. 32, IV, do Regulamento do Novo Mercado (pós reforma/2017), que demanda a aprovação pelo CA de uma política de transações com partes relacionadas.

⁹ Apenas a título comparativo, observe-se que, quanto ao disposto no *caput* do art. 115, a respeito da configuração de abuso do direito de voto (ainda que não seja essa a disposição que cuida, especificamente, da questão do conflito de interesses), a LSA remete apenas ao “fim de causar dano” e à vantagem de que “resulte, ou possa resultar, prejuízo”; ou seja, considera para tal fim a aptidão para causar dano ou prejuízo, mas não a materialização em si (o que, por óbvio, será, de todo modo, necessariamente apurado quando se estiver a tratar de pretensão indenizatória propriamente dita).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

má-fé do acionista potencialmente conflitado, o que me parece conduzir o debate a uma seara impertinente, uma vez que o prisma do conflito formal não está assentado em presunção de abuso ou má-fé, e sim na constatação de circunstância que inibe ou, no mínimo, compromete uma avaliação isenta, como acontece também em outros ramos do direito. Por exemplo, no caso de impedimento de voto, de um juiz ou membro de órgão decisório administrativo, para decidir em causa própria ou um caso que envolva familiares próximos, não se está a presumir-lhes má-fé ou propensão a abuso, mas sim a reconhecer que a isenção de seu juízo restará impactada e com o impedimento se preserva a higidez do processo decisório, independentemente de se formar, ou não, uma decisão melhor.

14. Reconheço, contudo, que, em muitos casos, o conflito de interesses não se revela de antemão de modo flagrante, ensejando inclusive grande dificuldade na análise sobre se de fato o acionista tem um “interesse conflitante” com o da companhia (e, quanto a isso, a LSA não nos socorre, já que não agregou elementos necessários para a configuração do conflito apto a gerar impedimento de voto)¹⁰. Especialmente em situações de relações indiretas ou em que o conflito seria vislumbrado de modo muito tênue, não cabe excessivo rigor na interpretação dita formalista, sendo preciso aprofundar o exame casuístico, a fim de não alargar indevidamente o âmbito da vedação legal imposta ao exercício de direito tão fundamental e de relevância ímpar para a governança corporativa, como é o caso do de voto, ainda que não se trate de um direito essencial nos termos do art. 109 da LSA¹¹.

15. Nessa linha, tomo emprestadas as ponderações do então Diretor da CVM Otávio Yazbek, em sua manifestação de voto no Caso Tractebel:

“Não acredito, assim, que apenas haja conflitos *in abstracto*, isolados das condições concretas das relações que se está constituindo. Pelo mesmo motivo, também não me parece que seja sempre possível identificar *ex ante* a existência de conflito ou que todas as matérias que envolvam controlador e controlada sejam, desde sempre, eivadas daquela conflituosidade. Reconheço mesmo que há casos em que este não

¹⁰ Foi o que, por exemplo, me levou a votar no seguinte sentido no Caso Linx/Stone: “(...) configura-se, a meu ver, situação de potencial conflito de interesses. Ocorre, entretanto, que, pelos elementos trazidos no Relatório e com as ressalvas já feitas neste voto, neste momento, não resta evidenciado que o interesse dos Recorrentes na aprovação da Operação Stone, mesmo consideradas as repercussões dos Contratos com Acionistas Fundadores, conflita com o interesse da Companhia; sendo que o impedimento decorreria justamente da existência de interesse conflitante. A esse respeito, acompanhando as bem fundamentadas razões da manifestação de voto do Presidente Marcelo Barbosa, concluindo, assim, que não restou demonstrado, neste momento, conflito de interesses apto a gerar impedimento de voto por parte dos Recorrentes em decorrência da celebração dos Contratos com Acionistas Fundadores, sem prejuízo, contudo, da verificação a posteriori quanto à regularidade do exercício do direito de voto (...)”, sem, contudo, ter deixado de admitir a possibilidade de existência de conflito apto, em tese, a impedir previamente o voto do acionista quando restar evidente a contraposição de seus interesses com os da companhia (PA CVM nº 19957.005563/2020-75).

¹¹ Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembleia-geral poderão privar o acionista dos direitos de: I - participar dos lucros sociais; II - participar do acervo da companhia, em caso de liquidação; III - fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais; IV - preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172; V - retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

seja passível de identificação, pelos potenciais prejudicados, quando da votação da matéria.”¹²

16. Parece-me, assim, que o exame em si quanto à configuração, ou não, de conflito de interesses requer uma análise substantiva (ou, para usar o mesmo termo, “material”), no sentido de que devem existir, no mérito, interesses efetivamente antagônicos, pois não há que se falar em conflito nem em impedimento de voto sem que haja real e substantiva contraposição de interesses.

17. Contudo, daí a se interpretar que não é possível a ninguém mais que não ao próprio acionista aferir, antes de efetivada a deliberação e da ocorrência de dano à companhia, se esse está conflitado, há uma larga distância, que entendo ser inconciliável com o tratamento dado pela própria LSA, na medida em que, na prática, acabaria por transformar a “vedação ao voto” em “autorização apriorística para votar”, sujeita apenas à posterior demonstração de dano a ser objeto de eventual contencioso (seja administrativo, judicial ou arbitral, com suas diferentes repercussões para as partes envolvidas), ainda que com isso se possa alcançar a anulação do voto.

18. Aplicada em sua inteireza, a teoria do conflito material, além de colocar o ônus da comprovação do conflito (como consequência da comprovação de dano), em regra, nos acionistas minoritários (com menores condições de acesso aos dados necessários à tal comprovação), acaba por frustrar a possibilidade de tutela preventiva à ameaça de violação do impedimento legal. Isso não me parece se coadunar com nosso sistema jurídico como um todo, que, em linhas gerais, ampara o uso de medidas e instrumentos preventivos ou cautelares disponíveis (seja administrativamente ou no âmbito judicial ou arbitral), mesmo que caiba reconhecer que, na prática, por vezes há insuficiência de meios para promover a agilidade e a efetividade necessárias, fazendo com que o exame da questão venha a se dar, usualmente, apenas após já ocorrido o descumprimento à lei.

19. De todo modo, não enxergo como contraditório com a proibição apriorística do voto em situação de conflito de interesses o fato de que os §§ 3º e 4º¹³ do art. 115 preveem que é anulável a deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da companhia e que o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido. Isso porque, em que pese a LSA proibir o voto do acionista conflitado, na prática esse pode ocorrer (ao arrepio da vedação legal) e, nesse caso, resta claro que a mera indenização por danos causados não será suficiente, sendo justamente a anulação o que levará ao *status quo ante*, fazendo jus à situação de impedimento prescrita em lei.

20. Assinalo, inclusive, que a sanção de anulabilidade cominada no § 4º é válida para todas

¹² V. PA CVM nº RJ 2009-13179 - Caso Tractebel, decidido em 09.09.2010.

¹³ § 3º O acionista responde pelos danos causados pelo exercício abusivo do direito de voto, ainda que seu voto não haja prevalecido. § 4º A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

as hipóteses de impedimento previstas no §1º, inclusive aquelas de caráter mais objetivo nas quais há consenso a respeito da aplicabilidade da vedação do voto *ex ante factum*. Assim, parece-me de todo equivocada a premissa defendida sob a ótica do conflito material de que o juízo acerca do conflito somente pode ser feito *a posteriori* e, portanto, o conflito de interesses não autorizaria o impedimento de voto, mas sim a anulabilidade do voto proferido em detrimento da companhia.

21. Ademais, pontuo que, tanto a respeito do art. 115 quanto dos demais dispositivos da LSA, não há qualquer restrição expressa a que a proteção do interesse da companhia *vis-à-vis* uma iminente perspectiva de voto por acionista em situação de conflito de interesses esteja circunscrita à utilização de remédios de reparação ou de anulação da deliberação (embora, como dito, essa via tenha sido explicitada no § 4º do art. 115), não havendo razão para, dogmaticamente, excluir a possibilidade de uso de ferramentas potencialmente preventivas (ainda que com suas inerentes limitações), seja perante a CVM¹⁴, seja em arbitragem ou pelo Judiciário, observados distintos escopo e alcance.

22. O argumento que remete à permissão legal contida no art. 117 da LSA para a celebração de negócios jurídicos entre a companhia e seu acionista controlador também não me parece convincente, seja por equiparar questões essencialmente distintas – autorização para contratar e autorização para votar –, seja por não levar em conta que, em grande parte dos casos, inclusive de transações com partes relacionadas, o contrato pode ser celebrado sem manifestação assemblear¹⁵.

23. Ademais, o mero controle *ex post* consoante assentado pela teoria do conflito material não é uma solução alinhada com o que é atualmente praticado em outros países com mercados de capitais de dimensões mais significativas¹⁶, notadamente em relação aos EUA¹⁷ e, ao menos desde

¹⁴ V., p.ex., Lei nº 6.385/1976: “Art. 9º (...) § 1º Com o fim de prevenir ou corrigir situações anormais do mercado, a Comissão poderá: (...) III - divulgar informações ou recomendações com o fim de esclarecer ou orientar os participantes do mercado; IV - proibir aos participantes do mercado, sob cominação de multa, a prática de atos que especificar, prejudiciais ao seu funcionamento regular”; e “Art. 13. A Comissão de Valores Mobiliários manterá serviço para exercer atividade consultiva ou de orientação junto aos agentes do mercado de valores mobiliários ou a qualquer investidor”.

¹⁵ Destaco trecho do voto do então diretor Marcelo Trindade no IA CVM nº RJ2001/4977: “O argumento de que o art. 117, § 1º, ‘f’, da Lei admite a contratação entre o acionista controlador e a companhia, em condições equitativas, parece-me, data venia, pouco expressivo. Ao discutir-se o impedimento do voto não se está discutindo a proibição de contratar, mas apenas a legitimidade do voto do controlador quanto à matéria. O contrato pode ser celebrado, desde que o beneficiário não vote. Além disto, é preciso lembrar que o contrato pode ser celebrado sem manifestação assemblear — o que, aliás, ocorre em grande parte dos casos —, ou sem a manifestação do voto do controlador, e ainda assim ele continuará respondendo, na forma do art. 117, se retirar benefício indevido como contraparte do negócio”. No mesmo sentido, cf. a manifestação de voto do então diretor Otavio Yazbek no Caso Tractebel.

¹⁶ Cf. precioso estudo comparativo conduzido pela ex-Diretora da CVM Luciana Dias, em desdobramento da sua tese de doutorado (*Transparência como Estratégia Regulatória no Mercado de Valores Mobiliários: Um Estudo Empírico das Transações com Partes Relacionadas*, Universidade de São Paulo: São Paulo 2014), foi traçado um panorama completo quanto ao tratamento de tais transações no contexto internacional, tanto à luz dos Princípios de Governança Corporativa da OCDE e G20, quanto no direito comunitário europeu, nos Estados Unidos e no Chile, evidenciando as dissonâncias do regime brasileiro frente aos seus pares internacionais (*As Transações com Partes Relacionadas no Direito Societário e a Lei de Melhoria do Ambiente de Negócios*, em vias de publicação).

¹⁷ A propósito dos precedentes julgados no estado norte-americano de Delaware, Rafael Vieira de Andrade de Sá destaca:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2017, aos membros da União Europeia¹⁸ (nem mesmo quanto ao regime adotado na Itália¹⁹, que, no passado, servira de inspiração, no Brasil, para a teoria do conflito material). Vale, também, considerar o retratado nos Princípios de Governo das Sociedades do G20 e da OCDE²⁰.

24. Com efeito, ainda que sem entrar nas especificidades dos sistemas jurídicos estrangeiros (seja quanto à legislação aplicável ou às regras de listagem nas respectivas bolsas de valores, quanto aos parâmetros e critérios adotados pelas respectivas instâncias decisórias, ou mesmo quanto ao funcionamento do sistema judicial), não se tem notícia de qualquer mercado relevante em que, na prática, acionistas controladores em situação de potencial conflito de interesses (como é o caso de deliberações sobre transações com partes relacionadas) simplesmente votem, a seu próprio critério, e

“(…) com o objetivo de obter o efeito de devolução do ônus probatório ao minoritário autor de uma ação de indenização, os controladores passaram a não mais votar nas deliberações que possuíam interesse ou então passaram a submeter a operação à aprovação de comitês especiais integrados por administradores. Mais recentemente, os controladores chegaram ao ponto de utilizar esses dois instrumentos de legitimação conjuntamente, uma vez que essa foi a única estrutura reconhecida como suficientemente capaz de conferir uma efetiva proteção aos acionistas minoritários. O incentivo para a adoção dessa estrutura reside na restauração da business judgment rule, que protege os controladores de uma eventual responsabilização judicial. Com isso, o modelo americano parece ter atingido um equilíbrio ideal entre proteção dos investidores e segurança jurídica” (O Entire Fairness Test no Direito Norte-Americano, Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, v. 79/2018, pp. 99-125, Jan-Mar/2018 DTR/2018/9066).

¹⁸ Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of The Council of 17 May 2017: “Article 9c **Transparency and approval of related party transactions** (...) 4. Member States shall ensure that material transactions with related parties are approved by the general meeting or by the administrative or supervisory body of the company according to procedures which prevent the related party from taking advantage of its position and provide adequate protection for the interests of the company and of the shareholders who are not a related party, including minority shareholders. Member States may provide for shareholders in general meeting to have the right to vote on material transactions with related parties which have been approved by the administrative or supervisory body of the company. (...) Member States may allow the shareholder who is a related party to take part in the vote provided that national law ensures appropriate safeguards which apply before or during the voting process to protect the interests of the company and of the shareholders who are not a related party, including minority shareholders, by preventing the related party from approving the transaction despite the opposing opinion of the majority of the shareholders who are not a related party or despite the opposing opinion of the majority of the independent directors” (grifos adotados).

¹⁹ Segundo esclarece Luciana Dias: “Como se percebe analisando o regime italiano, o regulador local usou muitas estratégias regulatórias diferentes – com especial ênfase no papel atribuído aos conselheiros independentes – e, muitas vezes, uma combinação de estratégias para lidar com os conflitos inerentes às transações com partes relacionadas, sempre procurando afastar a figura do controlador ou do administrador interessado da decisão. Em especial, para aquelas operações consideradas de maior relevância, o legislador italiano transferiu a decisão, ou pelo menos o poder de veto sobre ela, para um comitê de conselheiros desinteressados, sujeito a deveres fiduciários, com poder para participar de todo o processo de negociação e com capacidade de contratação de terceiros especializados para auxiliar na análise” (v. artigo referido na nota de rodapé 16).

²⁰ “2. (...) F. (...) **1. Os conflitos de interesse nas transações com partes relacionadas devem ser tratados.** (...) O potencial de abuso de transações com partes relacionadas é uma questão política importante em todos os mercados, mas, sobretudo, nos com concentração acionista e naqueles em que prevaleçam os grupos de sociedades. (...) Após a identificação das transações com partes relacionadas, as jurisdições definem procedimentos para a sua aprovação, de forma a minimizar o seu potencial negativo. Na maioria das jurisdições, é colocado grande ênfase na aprovação pelo conselho de administração, muitas vezes com um papel proeminente dos membros independentes, ou a exigência de que o conselho justifique o interesse da transação para a sociedade. Os acionistas também podem ter uma palavra a dizer na aprovação de determinadas transações, desde que excluídos os acionistas interessados” (grifei) (OCDE (2016), Princípios de Governo das Sociedades do G20 e da OCDE, OCDE, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264259195-pt>).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

sem observância de quaisquer procedimentos de mitigação ou salvaguardas, estando sujeitos apenas a serem desafiados *ex post* se houver comprovação de dano à companhia.

25. Ainda que seja fato que em certas jurisdições relevantes não há impedimento prévio de voto do acionista em assembleia previsto em lei²¹, a verdade é que a praxe ou as decisões de cortes competentes levaram à adoção de diversos mecanismos procedimentais e de salvaguardas que apostam, de um lado, no afastamento dos interessados no processo decisório pertinente a transações com partes relacionadas e, de outro lado, no escrutínio de comitês ou do CA, notadamente por seus membros independentes ou desinteressados, fazendo com que, em quaisquer casos envolvendo operações minimamente relevantes, as discussões travadas girem em torno da higidez do processo decisório, da independência e outras qualificações necessárias aos comitês especiais e membros independentes engajados no processo e de sistemas com aprovações apartadas (sem contar com os acionistas controladores) para legitimação por meio de aprovações pela “maioria da minoria”.

26. Lamento, assim, que depois de tantas décadas, ainda estejamos presos ao inglório embate entre as teorias do conflito formal e material – inclusive descolados das práticas e discussões que atualmente se travam no mundo – numa realidade em que, quanto a ambas as teorias, inclusive, se evidenciam insuficiências e inadequações que impedem uma clareza quanto ao tratamento jurídico da matéria no Brasil e, assim, corroem a segurança jurídica²². A propósito, destaco, também, a crítica bem assentada pelo então Diretor da CVM Gustavo Borba, em seu voto no Caso Eneva:

“Entendo que tanto a teoria formalista como a materialista possuem fragilidades e engendram inconveniências práticas, uma vez que, enquanto a primeira reduz demasiadamente o poder majoritário, a segunda cria grande insegurança e subjetivismo, afetando a estabilidade das relações societárias com o incremento da possibilidade de anulação - apesar das intensas discussões já travadas (nenhuma unânime), parece-me que a matéria ainda se encontra em evolução. Na análise do presente caso, contudo, até mesmo por razões de segurança jurídica, seguiremos a linha de raciocínio formalista, que já há muito tempo prevalece na CVM. (...) Essa configuração fática [do caso concreto] geraria, na linha formalista, situação de conflito de interesse (...)”²³

27. Nesse contexto, esclareço que, em relação ao conflito de interesses de acionista perante a

²¹ Como é o caso, por exemplo, da legislação do Estado de Delaware, nos EUA.

²² Como bem pontuado pelo ex-Diretor Gustavo Borba, ao justificar seu voto no Caso Emae: “*Alinho-me, no presente voto, à teoria formalista, não apenas porque entendo que essa posição está em sintonia com o texto legal (art. 115, § 1º, da LSA), mas, principalmente, por me parecer inadequado, considerando razões de segurança jurídica, prolongar uma discussão que já dura mais de 15 anos, sem que existam razões robustas para tanto. Ressalvo, no entanto, que praticamente todos os precedentes que decidiram pelo impedimento de voto em virtude de conflito envolviam situações de inequívoco antagonismo entre os interesses do acionista e da sociedade, e, na maioria das vezes, apreciavam a posição do acionista como contraparte da sociedade na operação a ser submetida à aprovação da assembleia*”, tendo ele, ainda, ressalvado que: “*Acredito que a configuração do impedimento de voto, em casos (...) que não envolvem interesses manifestamente antagônicos (“contraparte”), ainda necessita maior aprofundamento e discussão (...)*” (em 26.09.2017).

²³ V. PA CVM nº RJ2015/5021, decidido em 25.08.2015.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

companhia, não me filio à adoção automática do que por vezes é referido como “conflito formal”, em que o apontamento objetivo quanto a uma determinada posição contratual por si só ou a mera existência de um dado direito seria suficiente para a configuração do interesse conflitante, independentemente de detido exame casuístico, de mérito, quanto à contraposição de interesses. Tal rigor extremado, a meu juízo, poderia abarcar situações em que sequer há clareza quanto à existência de um interesse conflitante. Porém, muito menos me alinho à tese do conflito material, que, a pretexto de construir uma releitura sistemática de diversas disposições da LSA, me parece descolar do regramento legal claramente estabelecido como hipótese de vedação de voto, de impedimento, ainda por cima fixando requisitos de ocorrência de dano para a companhia, que, ao mesmo tempo, admitem não serem aplicáveis às demais situações elencadas no mesmo § 1º do art. 115.

28. Com efeito, a inadequação da tentativa de esgotar a matéria em um desses extremos já vem sendo, em certa medida, objeto de considerações em diversos votos apresentados em casos concretos no âmbito da CVM²⁴ e do CRSFN²⁵. Nesse passo, ainda que a maior parte dos casos apreciados pela CVM sejam de PAS e, portanto, examinem situações já ocorridas, existindo limitações de diversas ordens para um efetivo exame apriorístico em caráter preventivo, tem sido fundamental a análise pormenorizada das circunstâncias específicas do caso concreto, a fim de melhor explorar questão preliminar da identificação da própria existência, ou não, do interesse conflitante, antes mesmo de considerações sobre a concretização de dano (o que reclamaria aferição *a posteriori*),

²⁴ V., por ex., para citar brevemente menções a registros feitos em votos do Colegiado neste sentido: Caso Tractebel, Diretor Relator Alexsandro Broedel Lopes, j. 09.09.2010 (v. ressalvas e críticas feitas nos votos do Diretor Relator e do Diretor Otávio Yazbek); Caso Emae, decidido em 26.09.2017 (v. voto do Diretor Gustavo Borba); Caso Eneva, Diretor Relator Pablo Renteria, j. 25.08.2015 (v. voto do Diretor Gustavo Borba); PAS nº RJ2014/10556 (“Caso Taurus”), Diretor Pablo Renteria, j. 24.10.2017 (v. voto do Diretor Gustavo Borba).

²⁵ V., p.ex., ainda que relativo ao art. 156, as ponderações feitas no voto do Conselheiro Relator Thiago Paiva Chaves, quanto ao Processo CVM RJ2014/591 (Acórdão CRSFN 263/2018), j. em 12.12.2018: “34) *Embora a maioria da doutrina e jurisprudência da CVM utilizem as regras do conflito de interesse formal ou material para avaliar casos como esse, penso que polarizar as decisões talvez não seja a melhor solução para enfrentar o problema do conflito de interesse envolvendo administrador e companhia, que reconheço ser assunto bastante complexo.* 35) *Uma abordagem doutrinária mais recente, que entendo ser bastante adequada, e que, em minha avaliação, resulta na melhor aplicação para o mencionado artigo, busca por uma solução intermediária e conciliatória nessa discussão, não sendo voltada exclusivamente para um tratamento puramente formal, nem material.* 36) *No pensamento de Calixto Salomão Filho, considera-se como critério balizador para definir se o controle do conflito deve ser a priori (formal) ou a posteriori (material) a existência ou não de “forte perigo de comportamento incorreto”: “A tradicional classificação entre hipóteses de conflito de interesses formal e material deve então ser revisitada. Não para ser negada, mas sim para ser transformada em diferença entre situações em que se verifica forte perigo de comportamento incorreto e situações em que isso não ocorre. A diferença não é apenas semântica. Implica deslocar a questão da análise e comparação do ato e sua relação com o interesse social para a verificação da situação e dos deveres mínimos de cuidado de administradores e controladores. Retorna-se, como dito acima, portanto, aos deveres de cuidado e fiduciários não como disciplina substitutiva do conflito de interesse, mas como critério para sua apuração” (O Novo Direito Societário, Calixto Salomão Filho).* 37) *A adoção puramente da tese do conflito formal poderia ser em muitos casos bastante rigorosa. Da mesma forma, acolher invariavelmente o conflito material para lidar com todos os casos de conflito de interesse do art. 156 não me parece ser a forma mais eficiente de tratar a questão, vez que em muitos casos o conflito é flagrante, mesmo antes de o administrador deliberar propriamente o tema, não havendo porque se aguardar a manifestação do ato societário”.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

bem como do debate sobre quem poderá arbitrar se há ou não conflito de interesses e quando esse restará configurado, se *ex ante* ou *ex post* (i.e., com base na deliberação tomada).

Considerações sobre este caso

29. No caso de que trata este PAS, a acusação de violação ao art. 115, §1º, foi, a meu ver, ancorada em percepção equivocada de que o Acusado tinha interesse conflitante no que tange ao objeto da deliberação da AGE, em que pese a própria SEP tenha reconhecido que não havia deliberação assemblear a ser então tomada sobre a capitalização do AFAC. Entretanto, em razão da correlação dessa matéria com as constantes da pauta da AGE, a SEP entendeu que, mesmo se tratando de questão a ser debatida e deliberada *a posteriori* na RCA, era apta a colocar o acionista em situação de impedimento de voto na AGE, fazendo alusão expressa a tese do conflito formal²⁶.

30. A meu juízo, entretanto, neste caso, especificamente quanto à deliberação tomada na AGE de 31.10.2019, não há que se falar em interesse do Acusado conflitante com o interesse social.

31. Destaco que tal AGE não deliberou sobre a realização do AFAC²⁷ nem sobre o Aumento de Capital em si, tampouco sobre a capitalização do AFAC, não envolvendo questão quanto à qual o Acusado estivesse em posição efetivamente contraposta à Companhia.

32. Com efeito, como se verifica dos autos, a AGE tinha como ordem do dia deliberar sobre os seguintes itens: “(i) aumento do valor do capital social autorizado da Companhia e consequente alteração do art. 8º do estatuto social; (ii) inclusão de regra estatutária conferindo poderes ao conselho de administração da Companhia para, dentro do limite do capital autorizado, emitir bônus de subscrição”.

33. Em relação ao capital autorizado, a proposta da administração para a referida AGE consistiu em um aumento do montante de 20 milhões para até 66 milhões de ações, a demonstrar que sequer englobava um incremento necessário apenas à luz da capitalização do AFAC detido pelo Acusado (que compreenderia a emissão de aproximadamente 6,89 milhões de ações, considerando o valor do AFAC, de R\$ 10 milhões, e o Preço de Emissão, de R\$ 1,45), mas, sim, para o somatório disso com o montante necessário – e essa era sua maior parte – à emissão dos Bônus de Subscrição, no contexto do PRJ.

34. Segundo pontuou a Defesa, considerando a parcela do limite do capital autorizado anteriormente vigente que não havia ainda sido exaurida em aumentos de capital anteriores (de 20

²⁶ V. itens 95 a 99 do Termo de Acusação (Doc. 0997337).

²⁷ Registro, inclusive, que, a Área Técnica assinala que a “*operação de AFAC, celebrada em junho de 2018, teve como objetivo a injeção de recursos extraordinários na Companhia, de forma a permitir a continuidade de suas operações. Portanto, pode-se aferir que tal operação atendeu ao melhor interesse da Companhia, desde que sua aprovação tenha ocorrido de forma regular*” (item 105 do TA).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

milhões de ações)²⁸, já seria possível inclusive efetuar a capitalização do AFAC, embora tal limite não fosse suficiente para proceder também à emissão dos Bônus de Subscrição. Em tais circunstâncias, apesar de as matérias constantes da pauta da AGE estarem correlacionadas com a capitalização do AFAC, dentro do escopo de medidas necessárias para atender ao previsto no PRJ, verifica-se que, claramente, tinham um escopo bem mais amplo.

35. Para além da maior amplitude das matérias deliberadas na AGE, noto também que, apesar de o aumento do capital autorizado constituir etapa antecedente, as instâncias decisórias eram distintas e não havia previsão de que as deliberações relacionadas ao Aumento de Capital seriam interdependentes, de modo que o aumento do capital autorizado inclusive teria eficácia individualmente, independentemente da deliberação do CA quanto à capitalização do AFAC²⁹.

36. Isso explica, aliás, por que, na proposta da administração para a AGE, não constaram as informações pertinentes à capitalização do AFAC, como o Preço de Emissão e os critérios para a sua fixação, que seriam objeto de posterior deliberação pelo CA. A propósito, note-se que a própria SEP considerou que, do ponto de vista informacional, fora atendido o disposto no art. 135, §3º, da LSA³⁰.

37. Por esses motivos, entendo que a correlação existente entre a ordem do dia da AGE e a capitalização do AFAC não se presta a justificar uma dualidade de interesses contrapostos, de modo que, a meu ver, restou ausente o antagonismo que se apresenta como pressuposto fundamental para a caracterização do conflito de interesses, seja sob a ótica da teoria do conflito formal ou material.

38. Por fim, o voto do Diretor Relator também analisou o voto do Acusado na AGE sob o enfoque do benefício particular³¹. Nesse aspecto, compartilho da visão de que não se consubstanciou hipótese de benefício particular, com duas ressalvas de ordem conceitual.

39. A primeira se refere à interpretação dada pelo Relator de que também nessa hipótese incidiria a abordagem sob o prisma material, aspecto em que remeto às considerações feitas acima para a hipótese de conflito de interesses, para evitar repetições desnecessárias. Em acréscimo, destaco

²⁸ O que pode ser extraído da análise das atas de reunião do conselho de administração realizadas a partir de 28.04.2015, data da aprovação do limite de capital autorizado anteriormente vigente, arquivadas no site da CVM.

²⁹ Relewa lembrar que a assembleia geral é soberana em suas deliberações a respeito do capital autorizado e poderia, por exemplo, decidir pela aprovação de um aumento em valor diverso daquele proposto pelo CA, o que poderia, em última análise, vir a impactar a posterior decisão da administração quanto à capitalização do AFAC.

³⁰ Como ressaltado no TA, “a capitalização do AFAC não era matéria a ser deliberada em assembleia. Compete ao conselho de administração das companhias abertas fornecer os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na AGE, por ocasião da publicação do primeiro anúncio de convocação do conclave, o que foi feito pela Saraiva, em linha com o disposto no art. 135, § 3º, da Lei Societária” (Item 95 do Doc. 0997337).

³¹ Apesar de a Área Técnica ter concluído pela existência de conflito de interesses do acionista, acabou por causar alguma confusão ao fazer referência, no Item 107 do TA, a que “(...) embora seja possível afirmar que a atuação do acionista controlador convergiu com os interesses da Companhia, entendo que o exercício de voto do Sr. Jorge Eduardo Saraiva na AGE que deliberou matéria que, notadamente, o beneficiaria de modo particular, configura o exercício abusivo do direito de voto (...)”. De todo modo, a própria SEP também reconheceu ali que são hipóteses conceitualmente distintas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

apenas a precisa consideração trazida pela Diretora Relatora Luciana Dias no julgamento do PAS CVM nº RJ2013/6635, em 26.05.2015, quanto à confluência das hipóteses sob o mesmo propósito:

“O impedimento de voto nasce da necessidade de expurgar da assembleia geral os acionistas que tenham interesses próprios na deliberação a ser tomada e que, por isso, possam privilegiá-los, preterindo os interesses da companhia e dos demais acionistas. Em outras palavras, o impedimento de voto dos acionistas que possam se beneficiar de modo particular com a deliberação, seja na hipótese de benefício particular ou de conflito de interesses, é uma medida de proteção à legitimidade da assembleia e da decisão nela tomada.”

40. A segunda diz respeito ao entendimento do Relator de que as hipóteses de benefício particular e conflito de interesses distinguem-se na medida em que a primeira compreenderia uma vantagem lícita, enquanto a segunda envolveria uma vantagem ilícita³².

41. Para não me estender, valho-me neste ponto do seguinte trecho do bem lançado voto do então Diretor Otávio Yazbek no Caso Tractebel, por sua clareza e pertinência:

“[A]inda que se siga a linha de que conflitos apenas podem ser identificados ao produzirem efeitos (quando do reconhecimento da ilicitude dos seus resultados, portanto), isso não autorizaria dizer que um conflito só existe quando aquele efeito danoso tenha se produzido. O conflito já existia antes, os interesses contrapostos já existiam – difícil era a sua identificação. Indo além, dizer que conflitos de interesses correspondem a vantagens ilícitas, neste contexto que ora descrevo, equivaleria a dizer que qualquer contratação realizada quando havia aquele tipo de contraposição seria, também, ilegal.

Ora, tanto não há ilicitude nas contratações que, como já exposto, a Lei não proíbe relações em que interesses contrários estejam envolvidos. Em suma, nos casos de posições contratuais contrapostas entre acionista e sociedade (e uma vez afastada a hipótese do benefício particular), muitas vezes podem existir interesses contrapostos (ou seja, o conflito de interesses propriamente dito). Nem por isso há, aí, ilicitude. Entendo que equiparar o interesse existente em caso de conflito de interesses a interesse ilícito, assim, gera uma dificuldade insolúvel.

Tanto assim que, para mim, o que a Lei cria, ao lidar com os conflitos de interesses, é um regime protetivo da integridade da formação de vontade da sociedade. Ilicitude, reitero, decorreria apenas da abusividade do voto propriamente dita, da obtenção daqueles efeitos vedados por lei, estes sim muito provavelmente apenas apuráveis em momento posterior.

Neste sentido, e apenas para fazer uma síntese, entendo que benefício particular e conflito de interesses distinguem-se porque, no primeiro caso, se está tratando de vantagens que diferenciam os acionistas exclusivamente na qualidade de acionistas. Já no segundo, os envolvidos podem figurar sob outro manto, como partes contratantes, por exemplo. A confusão entre as duas categorias talvez esteja relacionada não apenas aos debates acima referidos, mas também ao fato de que, em ambos os casos, no fundo, talvez se esteja falando em conflito de interesses em sentido amplo.”

³² Conforme parágrafo 136 do voto do Diretor Relator.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

42. No mais, entendo que os elementos que afastam a existência de benefício particular no caso foram bem delineados no voto do Relator.

43. Pelo exposto, ainda que com base em fundamento diverso, acompanho o voto do Diretor Relator pela absolvição do Acusado quanto à suposta violação do disposto no art. 115, § 1º, da LSA.

Vedação de intervenção e de voto do Administrador Conflitado – art. 156 da LSA

Considerações Gerais

44. Em relação à acusação formulada em face do Acusado, na qualidade de membro do CA, de violação ao art. 156 da LSA, por ter votado na RCA aprovando matéria na qual tinha interesse conflitante, respeitosamente, divirjo tanto do fundamento quanto da conclusão do Relator.

45. Entendo, inclusive, que a teoria do conflito material não deve ser transposta para a interpretação do disposto no art. 156 da LSA sem maiores considerações e ponderações acerca das diferenças existentes entre as posições de conflito de interesses de acionistas e de administradores, em relação à companhia, correlacionadas com os demais deveres fiduciários dos administradores.

46. Novamente, tomando como ponto de partida o dispositivo legal objeto da acusação, vale repisar que o *caput* do art. 156 da LSA disciplina a vedação aplicável aos administradores de “intervirem em qualquer operação” em que tiverem “interesse conflitante com o da companhia” e de participarem “na deliberação” dos demais administradores a respeito de tal operação. Em textual:

“Art. 156. É **vedado** ao administrador **intervir** em **qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores**, cumprindo-lhe cientificá-los do seu **impedimento** e fazer consignar, em ata da reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse.” (grifei)

47. Busca-se, com isso, impedir que o administrador se valha de sua posição chave no âmbito da companhia para influenciar a estruturação das bases do próprio negócio ou operação, bem como eventual decisão de aprovação da companhia, em defesa de seus próprios interesses, desviando-se do cumprimento dos seus deveres fiduciários.

48. Ademais, ainda que os acionistas também tenham o dever de votar no interesse da companhia, cabe frisar que o administrador tem um leque mais amplo de deveres fiduciários em relação à companhia e deve-se considerar, no âmbito das discussões travadas nesses casos, que o administrador integra a administração da companhia (seja como diretor ou membro do conselho de administração) e, dentro dos limites das suas atribuições e competências, lhe cabe trabalhar para obter, seja com seu esforço nas negociações ou nos debates internos sobre os termos e condições a serem negociados ou considerados, as melhores condições possíveis para a companhia.

49. É certo, também, que o dispositivo legal se refere genericamente ao interesse conflitante



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

do administrador para com a companhia, não tendo elencado deliberações específicas em que estaria impedido de participar das deliberações, devendo a avaliação quanto à existência do conflito de interesses também se dar à luz de cada situação em concreto.

50. Entende-se, a propósito, que o administrador deve se abster de participar da discussão³³ e deliberação da matéria em que configurado o conflito, cientificando os demais administradores e fazendo constar da respectiva ata o seu impedimento, explicitando a natureza e a extensão do conflito. Tem-se, portanto, a própria LSA determinando que o controle (e seu registro) se faça *ex ante*, ainda que pelo próprio administrador, independentemente de qualquer configuração de dano à companhia.

51. Nessa seara, considero ainda mais problemática a aplicação da teoria do conflito material para tratar da questão da configuração do conflito, da vedação a qualquer intervenção na estruturação ou negociação da operação, bem como do impedimento de voto do administrador conflitado.

52. Com efeito, no âmbito da CVM, a interpretação do art. 156 vem recebendo tratamento distinto do referido na Seção anterior quanto ao art. 115, § 1º, como já bem destacara o Diretor Relator Pedro Oliva Marcilio de Sousa, no PAS CVM nº RJ2005/1443, julgado em 10.05.2006:

“36. A questão do conflito de interesses dos administradores tem recebido tratamento muito diferente da CVM em comparação ao tratamento do direito de voto, em que se discute se o conflito é formal ou material (ver Inquérito 12/01). Para os administradores, vige o conflito formal. Esse tratamento diferenciado vem do próprio texto legal que, além de vedar a participação nos atos relativos à operação, determina que o administrador revele o conflito.”

53. Valendo-me, novamente, das palavras precisas da então Diretora Luciana Dias, desta vez em relação ao conflito de interesses de administrador, destaco o seguinte trecho de seu voto no âmbito do PAS CVM nº 09/2009, julgado em 21.07.2015:

“46. Conforme entendimento já consolidado pelo Colegiado da CVM, a tese que orienta a análise dessa situação é a do conflito formal de interesses, de modo que é vedada *a priori* a participação do administrador na operação em que se verifica o conflito, independentemente do conteúdo de seu voto e de seu objeto vir ou não a se alinhar com os interesses da companhia. Não me parece haver dúvidas também de que esta orientação perdura inclusive diante de orientações em sentido contrário recebidas dos acionistas que o elegeram ou signatários de acordos devidamente registrados na sociedade.”

³³ A propósito, vale destacar o que dispõe o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC (2015 – 5ª edição): “5.4 **Conflito de Interesse. Fundamento.** Os conselheiros, assim como os executivos, têm dever de lealdade com a organização e não apenas com o sócio ou grupo de sócios que os indicaram ou elegeram. Há conflito de interesses quando alguém não é independente em relação à matéria em discussão e pode influenciar ou tomar decisões motivadas por interesses distintos daqueles da organização. **Práticas (...)** c) A pessoa que não é independente em relação à matéria em discussão ou deliberação deve manifestar, tempestivamente, seu conflito de interesses ou interesse particular. Caso não o faça, outra pessoa deve manifestar o conflito, caso dele tenha ciência. Tão logo identificado conflito de interesses em relação a um tema específico, a pessoa envolvida deve afastar-se, inclusive fisicamente, das discussões e deliberações. Esse afastamento temporário deve ser registrado em ata”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

54. E, sem pretender reproduzir diversas outras manifestações de voto que abordaram a matéria com muita propriedade³⁴, permito-me trazer, ainda, a excelente síntese feita pelo Diretor Relator Henrique Machado Moreira, no PAS CVM nº 19957.011059/2019-71, j. em 22.09.2020:

“16. Em linhas gerais, caracteriza-se o conflito quando o administrador é detentor de interesse oposto, antagônico, ao interesse da companhia. Os exemplos clássicos são aqueles em que o administrador é a própria contraparte da companhia, seja diretamente, seja por meio de pessoa jurídica na qual detém participação relevante. Muitas, porém, são as nuances que envolvem a análise quanto à configuração do conflito de interesses, a exigir a consideração das circunstâncias específicas de cada caso.

17. A extensão do art. 156 da Lei nº 6.404/1976 tem sido objeto de inúmeros debates doutrinários e jurisprudenciais. Consoante entendimento já consolidado do Colegiado, a tese que orienta esse dispositivo é a do conflito formal de interesses, que impede *a priori* (e não à luz do sentido do seu voto) a participação do administrador nas situações em que tiver interesse conflitante com a sociedade.”

55. Quanto à aplicação do disposto no art. 156, também já tive a oportunidade de me manifestar³⁵, em linha com entendimento reiterado do Colegiado³⁶⁻³⁷, no sentido de que o art. 156, *caput*, configura hipótese de conflito formal de interesses, tendo ressalvado que tal dispositivo não abrange qualquer situação em que se verifique potencial falta de isenção por parte do administrador.

56. Isso não afasta, por óbvio, a complexidade trazida pela questão basilar e preliminar que se coloca de, diante das circunstâncias do caso, avaliar se resta ou não configurada a existência de “interesse conflitante” do administrador, então não se pode dizer que não sejam casos desafiadores.

57. De todo modo, importa destacar que a análise da vedação trazida pelo art. 156 apresenta importantes diferenças em relação à questão do impedimento de voto em assembleia geral.

³⁴ V., p.ex., PAS CVM nº RJ2014/4077, Diretor Relator Henrique Machado, j. em 26.02.2019; PAS CVM RJ2012/3110, Diretor Relator Pablo Renteria, j. em 14.02.2017; PAS CVM nº RJ2014/591, Diretor Relator Roberto Tadeu Fernandes, j. em 27.09.2016; Proposta de requalificação, aprovada por unanimidade, na reunião de Colegiado de 19.05.2015 a respeito do PAS CVM nº RJ2011/11073, Diretor Relator Pablo Renteria, j. em 15.12.2015; PAS CVM nº RJ2013/11699, j. em 02.09.2014, PAS CVM nº RJ2013/1840, j. em 15.4.2014, e PAS CVM nº RJ2011/14269, j. em 23.03.2013, os três de relatoria da então Diretora Ana Dolores Novaes; PAS CVM nº 03/04, j. em 23.05.2007 e PAS CVM nº RJ2005/0097, j. em 15.03.2007, ambos de relatoria da então Diretora Maria Helena Santana; IA CVM nº 04/1999, Diretora Relatora Norma Jonssen Parente, j. em 17.04.2002; IA CVM nº 32/2000, Diretor Relator Marcelo Trindade, j. em 10.10.2001.

³⁵ Quanto a infrações de violação ao art. 156 da LSA, para citar os de minha relatoria: PAS CVM nº 19957.004309/2016-73, j. em 03.12.2019; PAS CVM nº RJ2016/7929, j. em 29.09.2020; PAS CVM nº RJ2018/8272, j. em 23.03.2021; PAS CVM nº 05/2015, j. em 09.11.2021; e PAS CVM nº RJ2018/7872, j. em 14.12.2021.

³⁶ Em acréscimo aos já citados anteriormente, v. tb.: PA CVM nº RJ2004/5494, Diretor Relator Wladimir Castelo Branco, d. em 16.12.2004; PAS CVM nº 12/2001, Diretor Relator Pedro Oliva de Sousa, j. em 12.01.2006; PA CVM nº RJ2007/3453, Diretor Relator Sergio Weguelin, d. em 04.03.2008; PAS CVM nº 25/03, Diretor Relator Eli Loria, j. em 25.03.2008; PAS CVM nº 09/2006, Diretora Relatora Ana Dolores Novaes, j. em 05.03.2013; e PA CVM nº SP2015/0339, Diretor Relator Pablo Renteria, d. em 25.09.2018.

³⁷ Em que pese ter havido pontuais manifestações divergentes, não consegui identificar, ao menos em relação às últimas duas décadas, qualquer PAS CVM em que tenha prevalecido decisão de julgamento de administrador de companhia aberta com fundamento na aplicação da teoria do conflito material, seja no sentido da absolvição ou da responsabilização.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

58. Não à toa verifica-se que, mesmo entre defensores da adoção da tese do conflito material para fins do art. 115, §1º, há manifestações de voto corroborando a adoção da tese do conflito formal especificamente para fins de interpretação do disposto no art. 156 da LSA.

59. Pela clareza da exposição quanto às distinções entre a conduta esperada do acionista e a conduta esperada do administrador, vale transcrever o seguinte trecho do voto do ex-Presidente Marcelo Trindade no Caso AMBEV³⁸, em que então acompanhou o voto do Diretor Relator Wladimir Castelo Branco na linha do conflito formal para fins de interpretação do disposto no art. 156, § 1º:

“Com efeito, o tratamento da matéria na Lei 6.404/76 é bastante claro, estabelecendo-se basicamente, no caput do art. 156, que o administrador está impedido de votar em deliberações em que tiver interesse conflitante com o da companhia. O § 1º do mesmo artigo deixa evidente que o ato de contratar com a companhia é daqueles abrangidos pela norma do caput, pois ali se diz que o contrato, mesmo com a observância da regra do caput (isto é, abstenção do administrador conflitado), deve ser celebrado em bases equitativas.

(...) o art. 156 da lei atual fez incluir, em seu § 1º, regra estabelecendo (ou esclarecendo) a obrigação de equitatividade mesmo que o administrador se abstenha de votar (como deve, na forma do caput) e, coerentemente, inquinando de anulável o contrato celebrado com infração dessa regra do § 1º. Assim, será (e somente será) anulável o contrato quando celebrado com lesão aos interesses da companhia, quer o administrador vote, quer não.

Dir-se-á — e na verdade é o que basicamente diz boa parte da doutrina pátria — que este fato comprova que o administrador pode votar. A meu sentir, a conclusão é excessiva. O que a Lei fez, e muito bem, foi eliminar a errônea impressão de que a abstenção do administrador legitimaria a deliberação, ainda que por esta se aprovasse celebrar contrato lesivo. Deixou a lei claro que o que motiva a anulação é a lesão aos interesses da companhia, quer o administrador impedido participe, quer não.

Mas daí não se pode extrair a suposta aceitação, pela lei, da legitimidade de uma conduta que ela própria proíbe, com todas as letras: "É VEDADO ao administrador intervir em qualquer deliberação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores...".

(...) Já que o caput do art. 156 fala em "interesse conflitante", exatamente como o § 1º do art. 115, e a hipótese de interesse conflitante é, para a maioria da doutrina, a única hipótese do § 1º do art. 115 em que a violação do interesse da companhia não deve ser presumida, e sim analisada *a posteriori*, o mesmo raciocínio deveria prevalecer na interpretação do art. 156.

O argumento desconsidera, a meu sentir, algumas distinções entre a conduta esperada do acionista e a conduta esperada do administrador.

Tal diferença se manifesta não só na expressa referência a "contrato", no § 1º do art. 156 (que não existe no art. 115), como à obrigação do administrador de, mesmo não

³⁸ V. Decisão do Colegiado em Recurso movido contra decisão da SEP pela não abertura de Inquérito Administrativo, Processo CVM nº RJ2004/5494, em 16.12.2004.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

votando, "fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse".

No caso de um contrato que a companhia vai celebrar, a negociação das condições caberá à diretoria e, eventualmente, dependendo de sua relevância, ao Conselho. Portanto, a existência de um interesse paralelo do administrador que vai comandar ou participar ativamente das negociações poderá influenciar as próprias bases do negócio, suas condições, tendo em vista o interesse econômico do administrador, em oposição ou em paralelo ao da companhia.

Bem se vê a diferença entre a conduta que se espera do administrador, e a que se espera do acionista. Aquele representa a companhia, e obtém, com seu esforço nas negociações, as melhores condições possíveis para a companhia." (grifos adotados)

60. Sem retornar às considerações gerais feitas na Seção anterior, interessante registrar, ainda, que, no que tange a operações com partes relacionadas, as já referidas Diretivas da União Europeia editadas em 2017 adotam, como regra geral, o afastamento de qualquer administrador ou de qualquer acionista que tenha um interesse na decisão, e, embora o Estado Membro possa permitir que o acionista vote (o que, na prática, quando ocorre, vem acompanhado da adoção de diversos procedimentos e salvaguardas), de todo modo, não pode fazê-lo em relação aos administradores³⁹, independentemente de quaisquer procedimentos e salvaguardas⁴⁰. É mais uma ilustração relevante de que são cenários diferentes e, assim, do quanto a adoção da teoria do conflito material nessa seara traz um desalinhamento para o Brasil em contraste com o que prevalece em mercados mais desenvolvidos, valendo, novamente, considerar o retratado nos Princípios de Governo das Sociedades do G20 e da OCDE⁴¹.

Considerações sobre este caso

61. Em relação ao caso objeto deste PAS, cabe ressaltar o seguinte.

62. No TA, a SEP reconheceu que: "(...) *era do interesse da Companhia o aumento de capital*

³⁹ Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of The Council of 17 May 2017: "Article 9c **Transparency and approval of related party transactions** (...) 4. (...) *Where the related party transaction involves a director or a shareholder, the director or shareholder shall not take part in the approval or the vote*" (grifos adotados).

⁴⁰ Vale mencionar que o Código Brasileiro de Governança Corporativa (2016), integrado ao regime jurídico das companhias abertas por meio da Instrução CVM nº 586/2017, que criou o "Informe Brasileiro de Governança Corporativa" (hoje incorporada à Resolução CVM nº 80/2022), exige a divulgação quanto à adoção ou não de práticas relativas às transações com partes relacionadas, ainda que numa abordagem "pratique ou explique", destacando que: "5.3.1 O estatuto social deve definir quais as transações com partes relacionadas devem ser aprovadas pelo conselho de administração, com a exclusão de eventuais membros com interesses potencialmente conflitantes; (...)" (grifei).

⁴¹ "2. (...) F. (...) 2. **Os membros do conselho de administração e os gestores de topo devem ser obrigados a divulgar ao conselho de administração se têm um interesse material, direto ou indireto ou por conta de terceiros, em qualquer transação ou assunto que afete diretamente a sociedade.** (...) Sempre que seja declarado um interesse material, considera-se boa prática que a pessoa não participe em qualquer decisão que envolva a transação ou matéria e que a decisão do conselho de administração seja especificamente fundamentada contra a presença de tais interesses e/ou justifique o interesse da transação para a sociedade, nomeadamente mencionando os termos da transação" (OCDE (2016), Princípios de Governo das Sociedades do G20 e da OCDE, OCDE, Paris).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

*e posterior emissão dos bônus de subscrição, de forma a permitir a capitalização dos créditos abertos contra a Companhia. (...) Além disso, a deliberação do conselho de administração que aprovou a capitalização do AFAC era exigência dos credores da Saraiva para aprovação do plano. Entre diversas outras medidas relacionadas à composição dos interesses de seus credores, estabeleceu-se um regime específico para a categoria de credores fornecedores incentivadores, compreendendo a possibilidade de que estes utilizem seus créditos para adquirir bônus de subscrição emitidos pela Companhia, nos termos e condições ali previstos*⁴². Esses aspectos restaram incontroversos.

63. Ao formular a acusação de descumprimento do art. 156, a Área Técnica pontuou que o Acusado, na qualidade de presidente do CA da Saraiva, “*votou na deliberação que aprovou o aumento de capital e a emissão dos bônus, operações que permitiriam a capitalização do crédito que detinha - na qualidade de acionista controlador - contra a Companhia. Em outras palavras, a aprovação das matérias garantiu um benefício particular ao administrador*”. Ao mencionar o “benefício particular”⁴³, a meu ver, a SEP se referiu a espécie de situação de conflito de interesses em que o administrador não está isento por ser titular de prerrogativa, privilégio ou benefício pessoal – no caso, a conversão em capital de crédito detido apenas por ele, ainda que na qualidade de acionista, em face da Companhia.

64. De início, destaco que a Acusação não se insurgiu contra a legalidade do AFAC ou sua legitimidade e consonância com o interesse da Companhia. Também não colocou em discussão o quanto pactuado no PRJ ou o processo de sua negociação, tampouco trouxe elementos que comprovassem que o Acusado, na condição de administrador, teria intervindo nas negociações relativas aos termos e condições do Plano, que incluíam o Preço de Emissão para o Aumento de Capital mediante a capitalização do AFAC e emissão dos Bônus de Subscrição.

65. A esse respeito, ressalto, aliás, que apesar de o TA informar que Jorge Eduardo Saraiva ocupava a posição de diretor à época da celebração do AFAC, em 28.06.2018, seu nome constava no formulário de referência da Companhia vigente no período⁴⁴ como Presidente do CA, mas não como diretor. Também não restou demonstrado se ele teria integrado a diretoria durante o processo de negociação do PRJ, sendo, entretanto, incontroverso que na ocasião ele era presidente do Conselho.

66. De fato, como órgão de deliberação colegiada, o CA não tem atribuições executivas, razão pela qual não se pode presumir que os conselheiros teriam participado nas negociações do PRJ perante

⁴² Itens 111 e 112 do TA.

⁴³ Embora o termo não tenha sido expressamente referido no art. 156 da LSA, isso não afasta a possibilidade de que um benefício particular a que o administrador faça jus possa ser o elemento subjacente à configuração da situação de conflito de interesses do administrador, que não abrange apenas situações de contrato com partes relacionadas.

⁴⁴ FRE apresentado em 25.06.2018, disponível para consulta pública no site da CVM.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

os credores. Por outro lado, como se verifica dos autos, o Acusado é signatário do PRJ⁴⁵, na condição de acionista controlador da Companhia, sendo, portanto, a meu ver, possível presumir que, em alguma medida, ele teve participação direta nas negociações das condições da recuperação judicial⁴⁶.

67. A fim de afastar o reconhecimento do conflito de interesses, a Defesa argumenta que a capitalização do AFAC estaria em consonância com o melhor interesse da Companhia, pois seria medida exigida pelos credores da Saraiva para aprovação do Plano.

68. Mesmo que não se dispute que a capitalização em si do AFAC não se contrapunha ao interesse social (pelo contrário, a meu ver), o argumento não afasta a responsabilidade do Acusado em relação a sua participação e voto na RCA.

69. Dado que o Acusado figurava como titular de crédito detido em face da Saraiva, consubstanciado no AFAC, e que ao CA cabia deliberar sobre os parâmetros adotados para a fixação do Preço de Emissão pelo qual o seu crédito seria capitalizado, quanto ao que administrador e Companhia estariam em polos opostos, entendo restar configurada, no caso, uma situação de conflito de interesses, a impedir que participasse da formação da vontade da Companhia. A meu juízo, não se pode deixar de reconhecer que o Acusado, por ser titular do AFAC, tinha um interesse pessoal em que o preço de emissão para a sua conversão fosse o menor possível a fim de que recebesse um maior número de ações, em contraposição ao interesse da Companhia de alcançar o maior valor que possibilitasse a colocação do Aumento de Capital, de modo a obter o menor custo de capital.

70. Com efeito, embora essa situação de conflito tivesse se tornado mais tênue diante do que fora negociado no PRJ, entendo que esse conflito não se dissipou em razão da existência do Plano, como sugere a Defesa. Ainda que fosse do interesse da Companhia atender ao disposto no PRJ e, assim, em princípio, não reabrir discussão de preço de emissão com os credores, não se pode atribuir à deliberação do CA qualquer automaticidade, como se fora mera formalidade daí resultante. Afinal, justamente em tais debates e deliberação é que os conselheiros de administração teriam de, cumprindo seus deveres fiduciários, analisar se os parâmetros de fixação do Preço de Emissão não ensejariam uma diluição injustificada dos demais acionistas, o que foi, inclusive, objeto da outra acusação da SEP, corretamente rechaçada pelo Relator.

71. Do ponto de vista societário, a aprovação do Preço de Emissão acordado com os credores não é automática, do contrário se estaria descaracterizando a competência atribuída ao CA pela AGE e o próprio regime de responsabilidade dos administradores asseverado na lei acionária. Daí a importância de que a decisão do CA fosse precedida de análise quanto a se as negociações mantidas

⁴⁵ Doc. 1149087, p. 201.

⁴⁶ Nesse aspecto, divirjo da visão do Relator de que não haveria comprovação dessa participação direta do Acusado nas negociações da recuperação judicial (conforme itens 24, “ii”, e 52 do voto do Diretor Relator).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

com os credores da Companhia refletiam o valor econômico, sem diluição injustificada dos acionistas, inclusive à luz dos resultados do laudo e parecer técnicos elaborados pelos especialistas contratados.

72. Nesse contexto, o fato de o Acusado, titular do AFAC, ter participado da negociação, ou, ao menos, da celebração do PRJ, do qual era signatário, me parece ser mais um elemento a reforçar que a independência e o distanciamento do administrador em relação à matéria estavam afetados em aspecto em que necessariamente a sua posição (de acionista-credor) se contrapunha à da Companhia (devedora), a impedir que pudesse participar dos debates e deliberação acerca do Preço de Emissão.

73. Por fim, considero igualmente improcedente o argumento da Defesa de que não houve irregularidade já que o voto do Acusado não foi determinante para a aprovação da capitalização do AFAC, por ter sido unânime a decisão do CA, ou seja, aprovada pelos demais conselheiros. Ainda que esse aspecto possa se refletir como atenuante na dosimetria, não afasta a ilicitude da conduta daquele que vota em situação de conflito de interesses, uma vez que, a meu ver, a vedação deve ser observada independentemente do sentido da manifestação pretendida pelo administrador e dos efeitos que essa decisão venha a produzir sobre a companhia e que o art. 156 veda que o administrador conflitado possa intervir na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores.

74. Pelo exposto, concluo que o Acusado deve ser responsabilizado por ter votado na RCA aprovando os parâmetros adotados pela Companhia para a fixação do preço de emissão do Aumento de Capital e, assim, o próprio Preço de Emissão das ações para fins da capitalização do AFAC de que era titular em face da Companhia, razão pela qual se encontrava em situação de conflito de interesses.

Dosimetria

75. Em relação à dosimetria da pena, noto que se trata de infração praticada após a edição da Lei nº 13.506/2017 e qualificada como grave (art. 1º, I, do Anexo B à Resolução CVM nº 45/2021⁴⁷).

76. Entretanto, em que pese sua gravidade em abstrato, para fins de aplicação de penalidade, cabe avaliar também sua gravidade em concreto, quando diante das peculiaridades do caso. Neste PAS, destaco, em especial, a ausência de diluição injustificada (art. 170, §1º, da LSA), a situação econômico-financeira da Companhia e a indispensabilidade do Aumento de Capital à luz do PRJ, circunstâncias que restaram evidenciadas, como bem abordado no voto do Diretor Relator.

77. Nessa linha, considerando as características do caso acima apontadas, proponho a fixação da pena-base em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fazendo incidir, no percentual de 15% para cada, (i) atenuante pelos bons antecedentes do Acusado; e (ii) atenuante relativa ao fato de que a aprovação na RCA teria prevalecido mesmo que o Acusado não tivesse votado (o que, embora não

⁴⁷ Observando-se, ainda, que a configuração do descumprimento ao art. 156 da LSA como “infração grave” já estava prevista pela Instrução CVM nº 491/2011, bem como pela Instrução CVM nº 607/2019 que a revogou.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

descaracterize a infração, deve ser levado em consideração para fins de dosimetria da pena).

78. Por todo o exposto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/1976, e à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, voto pela condenação de Jorge Eduardo Saraiva, na qualidade de membro do conselho de administração da Saraiva, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), por violação ao disposto no art. 156 da Lei nº 6.404/1976, por ter votado na RCA de 03.11.2019, aprovando matéria na qual tinha interesse conflitante com o da Companhia. Quanto a todas às demais acusações, acompanho a conclusão do voto do Diretor Relator pela absolvição dos acusados.

É como voto.

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2022.

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.003175/2020-50

Reg. Col. nº 2007/20

Acusados: Jorge Eduardo Saraiva

Jorge Saraiva Neto

Olga Maria Barbosa Saraiva

Assunto: Apurar eventuais irregularidades em processo de aumento de capital social, relativas a **(i)** diluição injustificada, em infração aos arts. 153 c/c 170, §§1º e 7º, da Lei nº 6.404/1976; e ao art. 2º, IX, do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480/2009; e **(ii)** conflito de interesses, em violação aos arts. 115, §1º, e 156 da Lei nº 6.404/1976

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Manifestação Complementar de Voto

I. Introdução

1. Considerando que o julgamento deste Processo¹ ainda não foi concluído², com fundamento no art. 941, §1º, do Código de Processo Civil³⁻⁴ e em linha com precedentes deste Colegiado⁵ e do Superior Tribunal de Justiça⁶, apresento esta breve manifestação em

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no relatório deste caso (“Relatório”).

² Em 16.08.2022, o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, e o Diretor Otto Lobo acompanharam os fundamentos e as conclusões do voto que proferi, tendo apresentado manifestações de voto. Em seguida, a sessão de julgamento foi suspensa em virtude de pedido de vistas realizado pela Diretora Flávia Perlingeiro.

³ “Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. § 1º O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído.”

⁴ Aplicável subsidiariamente aos processos administrativos sancionadores por força do disposto em seu art. 15. *In verbis*: “Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.”

⁵ A título exemplificativo, cito os PAS CVM **(i)** nº SP2017/0294, j. 03.11.2020; **(ii)** nº 19957.004122/2015-99, j. 12.04.2016; e **(iii)** nº 24/05, j. 07.10.2008.

⁶ Vide **(i)** STJ, HC 225082/PI, Ministra Relatora Laurita Vaz, j. 10.12.2013: “*Habeas Corpus. Penal. Crime de responsabilidade de Prefeito. Decreto-Lei n.º 201/67, art. 1.º, inciso I. Sessão de julgamento para recebimento da*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

complemento ao voto que proferi na sessão de julgamento de 16.08.2022 (“Voto”).

2. Meu objetivo aqui consiste em esclarecer um único ponto sobre o impedimento de voto em casos de benefício particular, ressaltando que todos os fundamentos e conclusões do Voto seguem inalterados, os quais ficam aqui reiterados de modo expreso.

II. Esclarecimento sobre benefício particular

3. Relembro que a Acusação, para fins de tipificação, fez menção a 3 institutos jurídicos distintos ao tratar da suposta violação do art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976 por Jorge Eduardo Saraiva. As irregularidades indicadas foram **(i)** abuso do direito de voto (*caput* do art. 115); **(ii)** benefício particular (art. 115, §1º); e **(iii)** conflito de interesses (art. 115, §1º, *in fine*).

4. Embora o caso concreto, a meu ver, se restrinja eminentemente a uma discussão referente a conflito de interesses, foi necessário que o Voto abordasse brevemente também as temáticas do abuso de voto e do benefício particular⁷.

5. Para fins de maior objetividade do Voto, em algumas passagens, optei por tratar de modo conjunto os institutos do benefício particular e do conflito de interesses. Foi nesse contexto que afirmei que o art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976 consubstancia hipótese de conflito material, sendo necessária uma análise da essência do benefício particular e dos interesses do acionista em conflito com os da companhia para que se avalie a regularidade do voto proferido na assembleia geral.

6. É importante que fique claro que, com a referência acima, pretendi essencialmente chamar a atenção para o fato de que o exame a ser realizado diante de caso que possa envolver benefício particular pressupõe, necessariamente, adentrar na essência da matéria que será deliberada em assembleia.

7. Apenas dessa forma será possível verificar, em uma situação específica, se está presente ou ausente alguma vantagem lícita que rompa o princípio de igualdade entre os acionistas

*denúncia. Voto do relator proferido. substituição. Retificação do voto pelo substituto. Impossibilidade. Acórdão nulo. Prescrição da pretensão punitiva. Ordem de habeas corpus concedida. 1. Enquanto não encerrado o julgamento, com a proclamação do resultado final, não há óbice à retificação, pelo julgador, de seu voto, ainda que se trate do relator da causa. Precedentes.”; e **(ii)** STJ, HC 64835 / RJ, Ministro Relator Felix Fischer, j. 22.05.2007: “Processual Penal. Habeas corpus. Julgamento de agravo em execução. Pedido de vista. Alteração de voto antes da proclamação do resultado. Possibilidade. Vedação quanto a essa hipótese se realizada a alteração por outro desembargador que atua em substituição àquele que já havia votado. Nulidade configurada. I - Esta Corte já firmou orientação de que, nos julgamentos colegiados, enquanto não proclamado o resultado e assim, não tiver ocorrido o encerramento do julgamento, é possível ao Julgador retificar ou alterar seu voto.” (grifos meus).*

⁷ As 3 abordagens foram enfrentadas na Seção III do Voto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

enquanto acionistas, requisitos necessários à configuração do benefício particular. Caso tais requisitos estejam presentes, será possível concluir pelo impedimento prévio de voto, *ex ante factum*, do acionista que será beneficiado particularmente pela deliberação assemblear.

8. A meu ver, é nesse sentido que o exame da configuração, *in concreto*, do benefício particular se aproxima do instituto do conflito de interesses e se distancia das hipóteses mais objetivas de impedimento de voto nominalmente previstas na parte inicial do art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/1976, cuja configuração é passível de ser verificada sem maiores exercícios interpretativos.

9. Apesar de tal semelhança, reitero meu entendimento no sentido de que, concluindo-se pela hipótese de benefício particular, restará configurado o impedimento prévio de voto, *ex ante*, do acionista beneficiado particularmente, de modo similar ao voto de acionista em deliberação relativa ao laudo de avaliação e à aprovação de suas próprias contas como administrador.

10. Trata-se de posição defendida por mim anteriormente⁸, em linha com o entendimento unânime da doutrina⁹ e diversos precedentes deste Colegiado¹⁰.

11. Falando especificamente sobre o caso concreto, como dito em meu Voto, reitero que “*não vislumbro no mérito do voto proferido pelo acusado na AGE qualquer benefício particular*”¹¹, de modo que não se fez presente a obrigação de impedimento de voto decorrente

⁸ Manifestação de voto por mim apresentada no PA CVM nº 19957.005563/2020-75, j. 13.11.2020 ([link](#)).

⁹ Alguns exemplos: (i) FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes, Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 575-577; (ii) ARAGÃO, Paulo Cezar. “Apontamentos sobre Desvios no Exercício do Direito de Voto”. In: CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro de; WARDE, Walfrido Jorge; GUERREIRO, Carolina Dias Tavares (coord.). Direito Empresarial e Outros Estudos de Direito em Homenagem ao Professor José Alexandre Tavares Guerreiro. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 194-195; (iii) TEIXEIRA, Lacerda; GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Das Sociedades Anônimas no Direito Brasileiro. vol.1. São Paulo: José Buschatsky, 1979. p. 277-278; (iv) GUERREIRO, José Alexandre Tavares. “Conflitos de interesse entre sociedade controladora e controlada e entre coligadas no exercício do voto em assembleias gerais e reuniões sociais”. In: Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro nº 51. Vol. 22. São Paulo: Malheiros Editores, p. 29-32, julho-setembro, 1983; (v) NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Conflito de interesses no exercício do direito de voto nas Sociedades Anônimas. In NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Temas de Direito Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2022. p. 87.

¹⁰ Como nos seguintes casos: (i) PA CVM nº RJ2011/9011, j. 16.02.2012 ([link](#)); (ii) PA CVM nº RJ2013/10913, j. 06.04.2014 ([link](#)); e (iii) PA CVM nº 19957.005563/2020-75, j. 13.11.2020 ([link](#)).

¹¹ “*Também não se faz presente a hipótese de benefício particular nas deliberações tomadas na AGE. O benefício particular refere-se a uma vantagem lícita, que a lei permite que seja concedida ao acionista, embora esta vantagem rompa a igualdade entre os acionistas. A contrario sensu, não havendo na lei palavras inúteis, se o acionista visasse a uma vantagem ilícita ou abusiva com o exercício do seu direito de voto, estaríamos diante de uma hipótese de conflito de interesses. O Aumento de Capital, como previsto no Plano e implementado pela Companhia, respeitou o direito de preferência dos demais acionistas, na forma do que determina a Lei nº 6.404/1976. Não se tratou de uma capitalização fechada, destinada exclusivamente ao acionista controlador, nem proibida de ser acompanhada por qualquer outro acionista da Companhia. A todos os acionistas foi aberto prazo*”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

da hipótese de benefício particular.

III. Conclusão

12. Ante o exposto, observada a ressalva de que a presente manifestação complementar não altera qualquer dos fundamentos ou conclusões do Voto, concluo no sentido de que **(i)** a hipótese de benefício particular, se constatada em um caso concreto, enseja o impedimento prévio de voto do acionista, *ex ante*; e **(ii)** nos autos, não estão presentes os elementos necessários à configuração do benefício particular, não havendo impedimento prévio de voto por parte do acionista acusado de violação ao §1º do art. 115 da Lei nº 6.404/1976.

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2022.

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator

para o exercício do direito de subscrição e integralização das novas ações pelo mesmo Preço de Emissão de R\$ 1,45 previsto no PRJ. O parâmetro de conversão do AFAC do acionista controlador em capital social foi rigorosamente o mesmo franqueado aos demais acionistas da Companhia.”